

en que se halla con una cosa determinada, pero continúa siendo normalmente uno solo.

No cambian tampoco, no obstante la apariencia contraria, cuando el mismo objeto es prometido a o por varias personas, de manera o con la inteligencia de que cada una deba entregar o de que a cada una deba entregársele una parte (como si se vende una cosa en condominio, o si una cosa en propiedad individual es comprada por varias personas que se proponen tenerla en condominio); aquí, por el principio común de la independencia de las cuotas (p. 251), se tienen tantas obligaciones distintas como sean los sujetos activos o pasivos.

En fin, considerando la relación desde el punto de vista del vínculo que liga entre sí a los sujetos, ni siquiera el hecho de que la prestación sea indivisible hace que las obligaciones múltiples recién descritas se fundan en una sola; la indivisibilidad es una característica del objeto, y el ordenamiento jurídico (con particular insistencia el derecho justiniano) proporciona, para cada hipótesis, los medios idóneos para evitar que produzca un desequilibrio entre los patrimonios de los diversos acreedores y deudores.

En cambio, hay casos (y a ellos se refiere en conjunto, en su más amplio significado, la denominación de la *solidaridad* y de las *obligaciones solidarias*) en los cuales, de un mismo hecho o acto jurídico surge obligación a cargo o en beneficio de varias personas, con el efecto de que aun siendo divisible el objeto de la prestación, ésta pueda ser reclamada por cada uno o a cada uno por la totalidad. Lo que sucede en dos casos profundamente distintos, según que se trate de obligaciones de delito o de acto lícito.

Ya se ha dicho (p. 409) que entre las características de las acciones que nacen del delito está la *acumulatividad* (o, como ahora podemos llamarla, *solidaridad acumulativa*); es decir que cuando varias personas han participado en el mismo delito, la acción se puede intentar conjunta o sucesivamente contra todos los coautores, cada uno de los cuales sufre la pena íntegra. Lo que deriva, como resulta claro, del concepto mismo de la pena y de la relativa venganza; del mismo modo que a una mente moderna repugnaría que los tres años de reclusión fijados por el art. 624 del Cód. Pen. it. se repartieran entre los varios culpables del mismo hurto, y más todavía que se le perdonasen al segundo por haber sido ya infligidos al primero, se renegaría de los conceptos romanos sobre el

delito y la pena privada si ésta no fuese íntegramente soportada por cada uno de los copartícipes. De este régimen de la solidaridad acumulativa se tiene testimonio de que todavía rige en la época justiniana para las acciones que nacen de los cuatro delitos típicos y para algunas de las que derivan de los actos ilícitos de derecho pretorio; pero un análisis detenido de los textos de la compilación hace que él se vislumbre, aun a través de las supraestructuras de soluciones nuevas, como clásicamente aplicado a toda obligación nacida de acto ilícito.

Muy distinta es la estructura de las obligaciones *in solidum* en el campo contractual; aquí la solidaridad tiene el fin de asegurar el cumplimiento, haciendo que el acreedor pueda dirigirse por la totalidad contra uno cualquiera de los codeudores (solidaridad pasiva), o que uno de los coacreedores pueda dirigirse por el todo contra el deudor (solidaridad activa). Pero puesto que, por lo menos desde el punto de vista económico, la obligación es única (la oscilación de la terminología de los juristas entre la *una obligatio* y las *plures obligationes* no merecía, en verdad, las largas discusiones que ha provocado), debe ser satisfecha una sola vez. Para justificar este resultado, los romanos consideran como *eadem res*, no obstante la diferencia de las personas, el vínculo que liga a todos los deudores y acreedores de la relación compleja; de allí deriva la consecuencia de que aquella eficacia general extintiva correspondiente al pago se reconozca a todos los otros modos objetivos de extinción que funcionan *ipso iure*, como la *acceptilatio*, la novación, y aun la *litis contestatio*¹⁶.

Pero precisamente a propósito de la eficacia extintiva de la *litis contestatio*, los textos de la compilación justiniana están en contraste entre sí, pues mientras algunos afirman esta eficacia extintiva, otros la niegan, declarando que la obligación pasivamente solidaria queda extinguida no por la mera contestación de la litis entre uno de los deudores y el acreedor, sino por el hecho de que, en ejecución de la condena, el acreedor demandante haya obtenido el pago íntegro. Sobre esta duplicidad de soluciones, la doctrina

¹⁶ En cambio los modos de extinción subjetivos, es decir, dependientes de acontecimientos propios a cada codeudor o coacreedor, como la *capitis diminutio* y la confusión, y los que funcionan *ope exceptionis*, como el *pactum de non petendo* y la compensación, eliminan el vínculo sólo entre las personas a que se refieren.

moderna (y en particular la sutilísima obra de RIBBENTROP) distinguió dos tipos diferentes de obligaciones *in solidum* nacidas de contrato: las correales (así llamadas sobre la base del nombre de *conreus stipulandi* o *promittendi*, que algún texto da a uno de los varios acreedores o deudores por estipulación con relación a los demás) y las solidarias en sentido estricto. Pero en tanto que era fácil encontrar en aquella diversidad en los efectos de la *litis contestatio* una diferencia de tratamiento entre las dos categorías, mucho más difícil resultaba distinguir sus presupuestos; por ejemplo, se dijo que en la obligación correal existe unidad de obligación, en la solidaria pluralidad de obligaciones que tienen el mismo objeto; o bien que, mientras unas y otras presentan unidad e identidad de objeto, sólo las correales ofrecen unidad de causa; y así sucesivamente, variando indefinidamente la formulación, pero sin salir nunca del campo de la pura teoría. Lo que habría sido tanto más difícil, cuanto que aquella famosa diversidad de efectos vuelve a encontrarse aun comparando entre sí textos que parecían partir de presupuestos de hecho y de derecho perfectamente idénticos.

Las investigaciones críticas sobre los textos de la compilación justinianeana han cambiado, en gran parte, las bases de la discusión. En efecto, ASCOLI y EISELE (retomando contemporáneamente una idea ya enunciada en el siglo XVI por CUIACIO) han establecido que aquellas contradicciones entre los textos obedecen, en su mayor parte, a una innovación de JUSTINIANO, quien en una constitución del año 531 (C. 8, 40, 28) estableció precisamente que la elección (*electio*) de uno de los fiadores o de los *duo rei promittendi* y la *litis* trabada con éste no liberaba a los otros mientras el acreedor no hubiese obtenido plena satisfacción. Establecido esto, resulta evidente, por lo menos en cuanto respecta al régimen de la estipulación con deudores múltiples, que los textos que contienen la mención de la eficacia extintiva de la *litis contestatio* representan otros tantos olvidos de los compiladores al corregir el dictado de los antiguos juristas, mientras que aquellos que niegan tal eficacia han sido adaptados a la reciente reforma.

El resultado no es desdeñable, porque indudablemente, aquí como en otros casos, la estructura formal de la *stipulatio* hizo que ella fuese preferida entre todos los contratos cuando se tratara de hacer nacer obligaciones *in solidum*. A este fin, la antigua jurisprudencia

dencia debió evitar cuidadosamente tanto las formas productivas de novación (p. 442) como las generadoras de obligaciones de garantía (ps. 453 y ss.), y estableció (Inst., 3, 17 pr.) que, queriéndose constituir una obligación activamente solidaria, los distintos acreedores hicieran, uno después de otro, la misma interrogación (agregándole el segundo y los siguientes el pronombre *idem*), y al final el deudor común respondiese una sola vez para todos: *spondeo*; que queriéndose, en cambio, constituir una obligación pasivamente solidaria, el acreedor dirigiese sucesivamente la misma interrogación a cada uno de los deudores, y al final éstos respondieran conjuntamente: *spondeo*.

Con esto no está todavía dicho que donde quiera que un contrato cree una obligación *in solidum*, ésta deba producir efectos exactamente iguales a los de la obligación emergente de estipulación correal. La completa equiparación es demostrable y está demostrada para varios casos: así, para el legado (*per damnationem*) subjetivamente alternativo, que se tiene cuando el testador pone la obligación a cargo indistintamente de uno o del otro de sus herederos ("Titius heres meus aut Maevius heres meus decem Seio dato"); para las deudas y créditos bancarios contraídos por *argentarii socii*; para las acciones *quod iussu, exercitoria, institoria, de peculio*, etc. (cfr. p. 107), de las cuales concurren los extremos respecto de varios condóminos del mismo esclavo; y quizá para algún otro.

Pero hay casos respecto de los cuales es difícil establecer si el derecho clásico mantuvo la eficacia extintiva de la *litis contestatio*. La citada constitución justiniana en C. 8, 40, 28, por ejemplo, comienza por declarar que quiere adaptar a los fiadores (y después a los *duo rei promittendi*) un régimen ya en vigor entre varios mandantes del mismo mandato de crédito (cfr. p. 454); y esto debe hacernos particularmente prudentes al negar fe al testimonio de D. 46, 1, 52 § 3, en el que se declara precisamente que la liberación de los *mandatores* no llamados a juicio sólo tiene lugar *pecunia soluta*. En el mismo sentido parecen deponer: para la obligación de los cotutores *ex communi gesto*, D. 26, 7, 18 § 1; para el depósito, D. 16, 3, 1 § 43; para el comodato y la locación, D. 13, 6, 5 § 15; pasajes éstos que, como los muchos otros que para diversos contratos repiten la misma enseñanza, podrían, tal como algunos sostienen, ser todos interpolados, pero que sus-

citan, sin embargo, serias dudas por el hecho de que no están, como los referentes a la estipulación, en contradicción con otros en los cuales se halle afirmada la eficacia extintiva de la *litis contestatio*. No debe excluirse que, aun habiendo tenido las obligaciones en cuestión una estructura inicial análoga a la de la obligación nacida de la estipulación correal, la jurisprudencia haya hecho después hincapié sobre el carácter de buena fe de las acciones relativas, para descartar la regla de la liberación como consecuencia de la *litis contestatio*; regla que se explica perfectamente con los principios del proceso romano, pero que, sin embargo, daba lugar en la práctica al resultado inicuo de dejar en descubierto al acreedor por el solo hecho de que hubiese intentado sin fortuna la litis contra el menos solvente de sus deudores. Si así fuese, se habría tenido precisamente en la época clásica una distinción entre obligaciones correales y solidarias (en el sentido de RIBBENTROP y de sus partidarios), y JUSTINIANO la habría abolido con la conocida constitución.

También en otro sentido, JUSTINIANO ha cooperado para reducir al mismo régimen la mayor parte de las obligaciones *in solidum*, eliminando, en una larga serie de casos, la responsabilidad acumulativa de los diversos autores de un hecho ilícito. Sin embargo, en esta parte no estableció un nuevo principio general, sino que conservó en varios casos la acumulatividad, y para la *actio legis Aquiliae* insistió en ella con particular tenacidad; pero frente a ciertos actos ilícitos del derecho pretorio, en los cuales el carácter delictuoso aparecía mucho menos evidente y la acción se dejaba fácilmente considerar desde el ángulo visual del resarcimiento del daño, encontró injusto e incorrecto que el ofendido se enriqueciese con la acumulación de las condenas pecuniarias, y reemplazó el viejo principio por otro, dominante en el derecho justiniano, de la liberación de todos mediante el pago de uno.

Según el derecho clásico, quien cumple con una obligación electivamente solidaria no tiene, por este solo hecho, una acción de regreso contra los codeudores, ni los coacreedores, contra el que ha recibido el pago, una acción para obtener la repartición. Regreso y división pueden derivar sólo de las relaciones especiales que median entre los *rei promittendi* o *stipulandi*, y en particular del contrato de sociedad; donde falta una relación de este género encontramos más ampliamente usado el *beneficium cedendarum*

actionum, es decir, la facultad del deudor que paga de hacerse ceder por el acreedor la acción que éste tendría contra los codeudores, pero es incierto si en esta aplicación el beneficio fuera clásico o justinianeo¹⁷. El derecho último auxilia más ampliamente a acreedores y deudores, concediendo acciones útiles adaptadas a las diversas hipótesis.

FRANJA
MORADA

¹⁷ Cfr. LEVY, ps. 224, n. 10, 237 y ss., y BESELER, 4, ps. 175 y ss. Mientras las dificultades no son muy graves para la cesión por el acreedor al fiador de la acción contra el deudor principal (la cual es intentada por el cesionario en la misma dirección y con los mismos efectos que habría tenido si fuera intentada por el cedente), aquí, en cambio, las acciones *parciarias* eventualmente concedidas al deudor que paga contra sus codeudores, tendrían objeto diverso del de la acción (*in solidum*) que habría correspondido al acreedor.

FRANJA MORADA

RELACIONES JURÍDICAS DE FAMILIA

CAPÍTULO XX

FAMILIA Y PARENTESCO

La palabra *familia*¹ tiene toda la variedad de significados que puede ser sugerida por la idea de la comunidad de vida y de bienes en el interior de la casa. Mientras a veces indica el patrimonio del jefe de la casa (como en la denominación de la *actio familiae erciscundae*, que sirve para la división de la herencia) o los bienes que en el tiempo del antiguo *consortium* entre consanguíneos se consideraban pertenecientes a la familia (como en la expresión *familiae pecuniaque*, que encontraremos en el testamento *per aes et libram*), más a menudo designa al jefe de familia y a las personas que de él dependen. Pero ni siquiera en esta última dirección se puede reconocer unidad de significado, porque aun entre los súbditos del jefe de familia la palabra *familia* comprende a veces sólo a los esclavos (como en la rúbrica edictal “*si familia furtum fecisse dicetur*”); otras —y con más frecuencia— sólo a aquellos dependientes que gozan del *status libertatis*.

En el centro de estas diversas acepciones de la palabra está la personalidad del *pater familias* y la férrea concepción de su potestad, que quita a los descendientes, mientras viva un ascendiente, toda capacidad de poseer y adquirir, y nivela, en cierto modo, a hijos y esclavos, hombres y cosas, en la uniforme sumisión a la voluntad del jefe. La circunstancia de que los hijos sean contrapuestos a los *servi* con la característica denominación de *liberi* no significa entonces que exista en el hecho una profunda dife-

¹ Para la etimología ver DEVOTO, “Atti Congr. Internaz. Dir. Rom.” (1933), Roma, 1, ps. 27 y ss.

rencia entre unos y otros desde el punto de vista del derecho privado, sino que sirve más bien para aclarar la antítesis entre el carácter permanente de la condición de esclavo y la natural transitoriedad del vínculo de sujeción doméstica que liga a los hijos con el padre.

Entre los significados que se han visto, tiene mayor valor técnico, por lo menos en la época avanzada, el que bajo la denominación de *familia* comprende al jefe de la casa y a las personas libres eventualmente sujetas a su potestad; tales son los descendientes, inmediatos y mediatos, como también la mujer, las nueras y las mujeres de los nietos cuando estén sujetas a la *manus* (*infra*, ps. 487 y ss.).

Pero la existencia de éstos que se pueden llamar miembros pasivos de la familia, es —ya se ha dicho— eventual, y también quien no tiene personas sometidas a potestad, siempre que no esté sujeto a nadie, es jefe de familia, no sólo en potencia sino en acto; por eso se dice que la mujer, que no puede tener a nadie bajo su dependencia, "*familiae suae et caput et finis est*".

De la persona sujeta a potestad de otra (no importa si libre o esclava) se dice que es *alieno iuri subiecta*, o más simplemente *alieni iuris*; del jefe de familia se dice que es *sui iuris*. Menos técnica es la expresión *pater familias*, la cual, en tanto indica a veces el mero *status* de una persona *sui iuris*, se la ve empleada predominantemente con relación a los adultos que gozan de la plena capacidad de obrar (así se dice que el pupilo sometido a tutela es *sui iuris*, pero no es usual llamarlo *pater familias*); más raramente todavía se da a la mujer *sui iuris*, sólo en cuanto tal, el nombre de *mater familias*, reservado generalmente a las madres de familia en el significado moderno de la palabra.

En el sentido últimamente analizado, la familia es (por lo menos en la época histórica) un organismo de breve duración; en efecto, quienes a la muerte del *pater familias* son sus descendientes inmediatos (los hijos, los nietos de quienes haya premuerto el padre, la viuda hasta entonces *in manu*, la nuera de quien haya premuerto el marido) se hacen, a su vez, jefes de familia, de manera que la familia paterna se fracciona en varias familias nuevas e independientes. Pero antiguamente el principio estaba atenuado en sus efectos por la costumbre de los consanguíneos de permanecer unidos en *consortium*, es decir, en una especie de "mano común" en virtud de la cual el patrimonio indiviso se con-

sideraba perteneciente a todos y a cada uno; y aun cuando la multiplicidad de los recursos y de las ocupaciones quebró esta comunión de familia, subsistió entre los que habían estado unidos bajo la misma potestad un vínculo de solidaridad moral y económica, que daba lugar a numerosas consecuencias jurídicas y era decisivo, sobre todo, en materia de sucesión y de tutela. De ahí la consecuencia de que el nombre de la *familia* se extendiese —aunque un poco impropriamente— a los parientes por vía masculina que habían estado anteriormente bajo la misma potestad o que hubieran podido estarlo si no se hubiesen producido muertes prematuras u otras circunstancias desfavorables; a la familia propiamente dicha, *familia proprio iure*, efectivamente reunida en torno a su jefe, se le opone como *familia communi iure* ésta que por la muerte del jefe se ha fraccionado.

Los componentes de la *familia* (sea *proprio*, sea *communi iure*) son, unos respecto de otros, *agnati*, y la relación de parentesco que hay entre ellos se llama *agnatio*; fundada sobre una potestad (actual o pasada, real o potencial), la agnación subsiste entre los que descienden de un común antepasado varón a través de otros varones².

El vínculo de agnación puede ser más o menos estrecho, o —como se prefiere decir— más o menos próximo; y se acostumbra computarlo por grados (*gradus*) considerando a las distintas generaciones como dispuestas en forma de escalera en cuya parte superior está el antepasado común. Entre descendientes y ascendientes (parentesco en línea recta) el grado está dado por el número de las generaciones: padre e hijo son recíprocamente ascendiente y descendiente en primer grado, abuelo y nieto en segundo, y así sucesivamente. En la línea colateral, en cambio, el grado se computa subiendo de generación en generación desde uno de los dos agnados hasta el primer antepasado común, y descendiendo luego hasta el otro agnado; así la agnación es de segundo grado entre hermanos (un grado ascendiendo desde uno de los hermanos hasta el padre, otro descendiendo desde el padre hasta el otro hermano), de tercer grado entre tío y sobrino (un grado en ascenso y dos en descenso), de cuarto entre primos, etc.

² En rigor, sin embargo, *agnati* son exclusivamente los colaterales: incluso hay textos que no llaman agnados ni siquiera a los hermanos, reservándoles el nombre de *consanguinei*. Pero se trata indudablemente de uso tardío.

Pero la *familia communi iure* no se extiende más allá de los límites permitidos por la ficción de supervivencia del antepasado común que está en su base; normalmente no se admite agnación más allá del sexto grado, lo que quiere decir —en línea colateral— más allá de los biznietos de un bisabuelo común o entre un nieto y un *abnepos*. Sólo excepcionalmente se admite una agnación de séptimo grado, entre un biznieto y el hijo de otro biznieto del mismo antepasado³.

Sin embargo, la denominación de *familia* se extiende también fuera del círculo de las relaciones de agnación, hasta abrazar toda una stirpe, es decir, los descendientes de un antepasado común real o supuesto, los que en el sistema onomástico romano llevan el mismo *nomen* (por ejemplo, los *Tullii*), o por lo menos todos los que, además de llevar el mismo *nomen*, se distinguen con el mismo *cognomen* (por ejemplo, los *Tullii Cicerones*). Por lo demás, la pertenencia a la *familia* así entendida, no produce consecuencias de relieve; es un vínculo social que adquiere importancia política cuando sirve para distinguir del resto de la población a la *nobilitas* de la época republicana avanzada, pero que no tiene ninguna influencia sobre el derecho privado.

Muy distinto es el caso para el patriciado de la antiquísima Roma. Aquí los descendientes de un antepasado común, real o supuesto, constituían una *gens*; y ésta no era la mera representación conjunta de muchas personas y familias jurídicamente autónomas.

³ El límite de la agnación al séptimo grado y su razón de ser son a duras penas reconocibles en un pasaje de MODESTINO sobre la *cognatio* (D. 38, 10, 4 pr.): "Non facile autem, quod ad nostrum ius attinet, cum de naturali cognatione quaeritur, septimum gradum quis excedit, quatenus ultra eum fere gradum rerum natura cognatorum vitam consistere non patitur". Entendiendo la última frase en el sentido de que no puedan coexistir parientes más allá del séptimo grado, se atribuiría a MODESTINO un error garrafal. Mejor que sustituyendo *vinculum* por *vitam*, como propone MOMMSEN (ad h. l.), el texto se hace inteligible interpretándolo como alusivo a la posibilidad de la coexistencia de los representantes de todas las generaciones a través de las cuales el parentesco se calcula, comprendido el primer antepasado común (así BRINI, en "Rendic. Accad. Bologna", 3, 1909-1910, ps. 36 y ss.). Depone en el mismo sentido el reconocimiento de un solo parentesco del 7º grado, el existente entre un primo segundo y el hijo de otro primo segundo (*sobrino natus*): caso de un bisabuelo que llegue, por excepcional combinación, a ser una vez tatarabuelo. Y tal criterio se explica sólo remontando de la cognación hasta la agnación, y vinculando la composición de la *familia communi iure* con la de la *familia proprio iure*.

sino un verdadero organismo jurídico. De él sólo podemos recoger los últimos indicios de vida; nuestros conocimientos seguros al respecto se limitan a lo siguiente: a falta de agnados, sucesión, tutela y curatela recaían antiguamente en los *gentiles*; es evidente que esta regla, cuyas modalidades de aplicación se desconocen, es el residuo de una mucho mayor eficiencia originaria de la comunidad gentilicia; pero la falta de noticias y la escasa credibilidad de los testimonios que nos han llegado de épocas muy posteriores a aquellas en que las *gentes* florecieron, ha creado en torno a esta institución toda una serie de hipótesis, en las cuales, muy a menudo, la historia es sustituida por mitos modernos. La opinión más probable es la de que el ordenamiento gentilicio hubiera sido propio de un grupo dominador (quizá el etrusco), dedicado a la ganadería y a la agricultura extensiva, que se habría superpuesto mediante la conquista a una población preexistente (latina); y de que la liberación de la población sometida se hubiera realizado a través del predominio de la agricultura intensiva, para servicio de la cual se habría desarrollado la nueva institución de la familia (*proprio* y *communi iure*)⁴. Según se ha visto oportunamente (ps. 203 y ss.), la propiedad inmobiliaria individual del jefe de familia plebeyo fué quizá precedida entre los patricios por un señorío territorial (*possessio*) ejercido en común por la *gens*. Sea lo que fuere, lo cierto es que la *gens* estaba ya en proceso de disolución en el tiempo de las XII Tablas; y, en los últimos siglos de la República, el Edicto pretorio, al revisar el régimen de la sucesión, pudo prescindir por completo de ella.

En este nuevo ordenamiento, en tanto que los miembros de la familia *communi iure* (colaterales agnados) conservan en buena parte los antiguos privilegios, al lado de la familia *proprio iure* se afirma la que se ha llamado "simple familia paterna", y que se funda sobre el vínculo de generación entre un progenitor varón y sus descendientes por justas nupcias, aunque hubieran sa-

⁴ Sobre el tema cfr. mi discurso inaugural sobre *La genti e la città*, en "Annuario Univ. Messina", 1913-1914; y para puntos de vista distintos BONFANTE, *Teorie vecchie e nuove sulle formazioni sociali primitive*, en *Scritti giur. varii*, I, ps. 18 y ss.; por último FREZZA en "Stud. et Doc. Historiae et Iuris", 4, 1938, ps. 363 y ss., y 5, 1939, ps. 161 y ss., y LUZZATTO, *Le organizzazioni preciviche e lo Stato*, Modena, 1948. Sobre la propiedad gentilicia en particular, cfr. MARCHI, en "Archivio Giuridico", 4ª serie, 2, 1921, ps. 60 y ss.; y en sentido contrario DE FRANCISCI, *Il trasferimento della proprietà*, ps. 46 y ss.

lido por emancipación de la potestad, a no ser que estén bajo la de un padre adoptivo. Prácticamente están equiparados a los hijos *patriae potestati subiecti* los que se han hecho *sui iuris*, porque fueron directamente emancipados por quien ejercía potestad sobre ellos o porque fueron dados en adopción por él a otro *pater* que después los emancipó. Veremos que precisamente a los descendientes así definidos les es deferida, en primer lugar, la herencia pretoria (cap. xxv, § 3), que la dote constituida para una de estas descendientes tiene el carácter de *profecticia*, que el *parens* —sea o no *pater* en el sentido de la *potestas*— tiene facultad de constituir dote para la hija en forma de *dictio* (p. 509); es el caso de recordar aquí que la obligación recíproca de los alimentos entre ascendientes y descendientes, que no hubiera tenido sentido en la *familia proprio iure* a causa de la incapacidad patrimonial del *filius familias*, se afirma cabalmente con relación a la nueva familia paterna⁵.

FRANJA

Familia proprio iure, *familia communi iure*, familia paterna, están informadas en el llamado principio patriarcal. El criterio que se halla en la base de este principio es el que los griegos llaman del “puro semen”, y que considera la obra de la generación como propia del padre. La mujer no puede tener hijos, ni como madre está ligada a la prole por agnación; sólo ficticiamente es considerada agnada de sus vástagos cuando ella misma esté bajo la potestad (*manus*) del marido o de quien ejerza potestad sobre él (entonces, en efecto, estando *loco filiae* respecto al marido, está *loco sororis* respecto a los hijos); pero en el matrimonio *sine manu*, que no hace salir a la mujer de la familia originaria, es una ex-

⁵ Sobre ella cfr. la investigación de MORLAUD, que desgraciadamente quedó inconclusa (*De la simple famille paternelle*, 1ª parte, Gênevê, 1909). Lo que digo respecto a los alimentos representa una ligera corrección a ALBERTARIO, *Sul diritto agli alimenti*, Milano, 1925 (= *Studi di dir. rom.*, I, ps. 249 y ss.); convencido como él de que la extensión del derecho y de la obligación a toda especie de ascendientes (paternos y maternos, legítimos y naturales) sea propia de la edad posclásica, no puedo, sin embargo, entender cómo en derecho clásico una obligación semejante haya podido introducirse precisamente a cargo de los *fili filiarum*, meros instrumentos de adquisición para el *pater*.

traña para los hijos. Tanto más son extraños entre sí los descendientes de una común antepasada, o también de un antepasado varón si en el orden de las generaciones por las cuales están vinculados a aquél entra una mujer; así los hijos de la misma madre y de padres distintos (hermanos uterinos), los nietos del mismo abuelo *ex filio* y *ex filia* pertenecen a distintas *familiae*, y el derecho de las XII Tablas excluye a su respecto la sucesión y la tutela legítima.

Pero la lógica de estas deducciones chocó bien pronto contra las exigencias del sentimiento jurídico. El parentesco materno, al que los romanos llaman *cognatio*, se presenta en la edad histórica como un vínculo potente, reconocido en todas las relaciones sociales, y ha tenido siempre reflejos jurídicos muy notables. Ante todo, en lo que se refiere al impedimento de parentesco respecto del matrimonio; si en otros países de régimen patriarcal, y, según parece, también en alguna parte de Grecia (por ejemplo, en Esparta), el principio del puro semen es aplicado hasta el punto de no considerar incestuosas las nupcias entre hermanos uterinos, el derecho romano ha equiparado siempre desde este punto de vista a agnados y cognados. Igualmente, en toda una serie de relaciones, en las cuales el vínculo de parentesco sirve para justificar el espontáneo empobrecimiento de una parte en provecho de la otra, para legitimar o para excluir una actividad judicial; así, la *lex Cincia de donis et muneribus* (año 204 a. C.), prohibiendo las donaciones que excedieran cierta medida, excluye de la prohibición a las donaciones hechas tanto a los agnados como a los cognados, especialmente si lo fueran con el fin de constituir una dote; así, muchas leyes de carácter criminal niegan a los cognados del culpable la facultad de acusar o de actuar como jueces, o reservan a los cognados de la víctima el derecho de acusación, o eximen a los cognados del acusado del testimonio, y otras disposiciones dan preferencia a los cognados en la vigilancia sobre el ejercicio de la tutela. La mayor resistencia de la familia agnaticia contra la invasión de estos nuevos elementos se ejerce en la sucesión; pero también respecto de esta última se hicieron muchas concesiones a fines de la República por el Edicto perpetuo, y más todavía en la época imperial, por los senadoconsultos Tertuliano y Orficiano, que regularon la sucesión entre madre e hijos. En el derecho justinianeo, la vieja agnación es abolida y el nombre de cognados se aplica indistintamente a los parientes por vía masculina y por vía

femenina, con absoluta paridad de derechos en todo orden de relaciones⁶.

Así es como para JUSTINIANO el conjunto de los agnados y cognados de una persona (*cognati* en el nuevo sentido) toma, a su vez, el nombre de *familia*; la palabra comprende ahora, en esta acepción, "*parentes et liberos omnesque propinquos*" (C. 6, 38, 5 pr.).

No hay que confundir con los parentescos hasta aquí mencionados, la *adfinitas*, es decir el vínculo que surge entre un cónyuge y los parientes del otro cónyuge. Sus consecuencias jurídicas son muy limitadas, reduciéndose a los ámbitos de los impedimentos matrimoniales y de la legitimación procesal.

*
* *

En la presente exposición, que se funda sobre el derecho romano clásico, se describe principalmente el régimen de la *familia proprio iure*; y puesto que la base de ésta se halla en la potestad del *pater familias*, se explican ante todo los modos de adquisición y de pérdida de las distintas potestades, y en consecuencia el contenido de ellas.

Decimos de las distintas potestades, aunque —como ya se ha observado— la autoridad del jefe de la familia igualase originariamente bajo sí misma a todos los sometidos a ella. La palabra *manus* debió expresar, en un primer momento, toda forma de

⁶ También para la cognación, el límite está normalmente en el 6º grado, salvo la hipótesis del *consobrinus* (hijo del primo segundo); aparte de las numerosas aplicaciones prácticas verificadas, especialmente en materia de sucesión, lo prueba el texto de MODESTINO citado en la p. 480, nota 3. La demostración de la normal ilimitación de la cognación, tentada por PEROZZI (*Studi in onore di B. Brugi*, 1910, ps. 267 y ss.), no parece alcanzada; solamente para la hipótesis de la donación con el fin de dotar a una cognada es cierto que la *lex Cincia* no fijaba límite de grado; pero también en esta hipótesis (y en otras eventuales para nosotros desconocidas) la conciencia social, y la jurisprudencia que era su intérprete, han debido, sin embargo, fijar un límite.

En el derecho justiniano, la Novela 118, reguladora de la sucesión legítima, es explícita en llamar a los cognados sin límite de grado. Pero precisamente de la interpretación de dicha norma de conformidad con las exigencias sociales partió en la época moderna la limitación (primero al 10º, después nuevamente al 6º grado).

poder sobre personas y cosas; lo demuestra el nombre de la *manu-missio*, que es el acto con el cual el dueño o cuasi dueño libera al esclavo o persona *in causa mancipii*, como así también el nombre de *mancipium* o *mancipatio*, que deriva de *manu capere* y expresa, según parece, el señorío sobre las personas y sobre las cosas más preciosas. Pero en la época histórica *manus* es solamente la potestad sobre la mujer o nuera o mujer del nieto; a su lado permanecen diferenciadas la *patria potestas* sobre los descendientes y la *dominica potestas* sobre los esclavos y sobre las personas *in causa mancipii*.

FRANJA
MORADA

FRANJA MORADA

CAPÍTULO XXI

EL MATRIMONIO

§ 1. EL MATRIMONIO COMO RELACIÓN PERSONAL

El matrimonio *cum manu* y sus formas: *confarreatio* y *coemptio*; función del *usus* en el traspaso al nuevo matrimonio *sine manu*. Estructura jurídica del matrimonio clásico y justiniano. Los requisitos para la validez del matrimonio: *connubium* y consentimiento. Limitaciones a la libertad matrimonial en las leyes augusteas de *maritandis ordinibus*, y hostilidad del Imperio cristiano hacia las segundas nupcias. Efectos del matrimonio.

En el examen de los modos de adquisición de la potestad, el matrimonio tiene doble importancia: ante todo en cuanto coincide, antiguamente, y también por excepción en la época clásica, con la adquisición de la forma de potestad que se llama *manus*; en segundo lugar, como principal fundamento, en toda época del derecho romano, de la *familia proprio iure*, es decir, como presupuesto de la patria potestad.

El matrimonio del más antiguo derecho romano es un acto o hecho jurídico en virtud del cual una mujer, *sui* o *alieni iuris*, sale de la familia de origen y entra en una nueva familia, en condición de sometida y con la particular función de procrear al jefe de familia o a uno de sus súbditos libres una descendencia legítima.

Los actos (negocios) jurídicos predispuestos a tal fin son dos: *confarreatio* y *coemptio*. La primera, que es una ceremonia religiosa cumplida quizá en presencia del *flamen Dialis*, y sin duda con la intervención de diez testigos, toma su nombre de una tortilla de farro dividida entre los esposos como símbolo de la vida común que se inicia; la segunda, en cambio, es una de las innumerables aplicaciones de la *mancipatio*, y consiste en una venta (efec-

tiva en los orígenes, ficticia luego) que quien ejerce potestad sobre la mujer hace de ella o que la mujer hace de sí misma al futuro marido o a quien ejerce potestad sobre él¹. Pero, así como en el sistema de los modos de adquisición de la propiedad los defectos de la *mancipatio* pueden ser suplidos con el goce ininterrumpido por uno o dos años (*usus, usucapio*), también los eventuales vicios de la *coemptio*, y quizá asimismo la falta de ésta, pueden ser suplidos con el *usus* anual.

La *conventio in manum* hace que la mujer pierda toda relación de dependencia y de parentesco civil (agnaticio) con la familia de origen, que quede sustraída a la tutela de los agnados, que cese toda expectativa sobre su herencia; en la nueva familia ella está *loco filiae* respecto del marido, *loco neptis* respecto del suegro, *loco proneptis* respecto del abuelo del marido, con todas las consecuencias favorables y desfavorables; si era mujer *sui iuris*, y como tal, titular de un patrimonio propio, se produce en beneficio de quien adquiere la potestad una sucesión a título universal.

Ahora bien; este paso de la mujer a la familia del marido debió desde *ab antiquo* resultar en muchos casos enojoso, no tanto por las expectativas de sucesión que quitaba a la mujer misma, como por la expectativa que quitaba al *agnatus proximus* sobre la herencia de la mujer; y puesto que el *agnatus proximus* era también el tutor de la mujer, esta circunstancia podía hacerle difícil el matrimonio. En consecuencia, se buscó un tipo de convivencia que no produjese la *manus*, y se lo encontró omitiendo la *coemptio* e impidiendo que el término del *usus* se cumpliera; las XII Tablas disponían que a este fin la mujer podía ausentarse cada año tres noches consecutivas de la casa conyugal (*usurpatio trinocitii*). Pero cuando tal práctica fué recogida por la ley, o por lo menos en un tiempo muy próximo, se debió admitir también que la permanencia de la mujer en el *status familiae* originario no perjudicase ni la legitimidad de los hijos ni su misma posición social, y que, en consecuencia, también aquella unión libre fuese matrimonial. Surge así el *matrimonium sine manu*, y desde los últimos siglos de

¹ Al lado de este tipo de matrimonio por compra, la leyenda romana nos ofrece también los vestigios del otro tipo de matrimonio practicado entre los pueblos primitivos, por raptó (cfr. el raptó de las Sabinas). No me parece digna de discusión, aunque sostenida por romanistas autorizados, la tesis según la cual los esposos se compraban recíprocamente.

la República ocupa un lugar tan predominante que puede ser considerado como el matrimonio típico del derecho romano.

En la época clásica, los modos que servían para contraer el matrimonio *cum manu* se nos describen como fuera de uso o excepcionales. El *usus* está del todo abolido por las *mores*, por evidente cesación de su función histórica. A los aspirantes a los altos cargos sacerdotales de *flamen maior* y de *rex sacrorum* se les exige que hayan nacido de nupcias contraídas mediante *confarreatio*; pero esto equivale a decir que solamente en un limitado círculo de personas, dentro del cual tales cargos se trasmitían (en el hecho) hereditariamente, se practicaba todavía la *confarreatio*². En cuanto a la *coemptio*, no parece que fuese más usada, salvo con extrema rareza, en su función originaria de negocio constitutivo del matrimonio, sino casi exclusivamente para fines particulares y derivados; por ejemplo, la mujer que quería sustraerse a la tutela de los agnados se dejaba *coemere* por un prestanombre, quien la mancipaba inmediatamente a otro hombre de confianza, y éste la manumitía y quedaba formalmente como su tutor (*coemptio fiduciae causa*). Estos últimos residuos también han desaparecido en el derecho justiniano.

*
* * *

Nacido como situación de mero hecho, que solamente con la continuación ininterrumpida por cierto tiempo (*usus*) se podía transformar en relación jurídica (matrimonio *cum manu*), el matrimonio *sine manu* ha conservado siempre una estructura conforme a sus orígenes, aunque en época todavía antigua haya sido reconocido como fuente inmediata de derechos y de obligaciones, es decir, como relación jurídica él mismo. No es, pues, como eran

² Está quizá en conexión con esto toda la serie de restricciones que regula la conducta de la *flaminica* y de la *regina sacrorum* en la vida pública y privada, y que ellas estén investidas de funciones particulares, que les dan una posición semisacerdotal, mientras que la mujer de cualquier otro sacerdote o magistrado no tiene derechos ni obligaciones distintas de los de las matronas en general. Por otra parte, precisamente con relación a estas nupcias celebradas mediante *confarreatio*, Tiberio limitó los efectos patrimoniales de la *conventio in manum*.

la *confarreatio* y la *coëmptio* y como es el matrimonio moderno, un negocio jurídico que se cumpla de una vez para siempre, a fin de producir en el tiempo sucesivo sus efectos, sino una relación continuativa, que mientras tiene efectos durables desde ciertos puntos de vista (por ejemplo, en cuanto se refiere a la legitimidad de los hijos), produce en otras esferas sus efectos por el tiempo que dura, mientras que cada una de las partes puede hacerla cesar cuando quiera.

Por estos caracteres que le son propios, el matrimonio romano ha sido comparado con la posesión; y es que, en efecto, por más que el matrimonio sea una relación jurídica y la posesión una simple situación de hecho, las dos instituciones tienen de común el hecho de apoyarse sobre dos elementos de duración: uno de hecho y externo (en nuestro caso, la convivencia entre marido y mujer); el otro, moral e interno (la *affectio maritalis*, o intención de tratarse recíprocamente como marido y mujer). Pero mientras en la posesión el elemento material de la disponibilidad de la cosa sobresale tanto que deja en las sombras al *animus rem sibi habendi*, aquí es el elemento moral el que domina, de manera que en general, por lo que se refiere a la continuación del estado conyugal ya iniciado, el elemento material se reduce en la práctica a una conducta de la cual resulte unívocamente la *affectio maritalis*.

Si en consideración a esta última circunstancia los juriscultos repiten con frecuencia que *consensus facit nuptias*, por ello no se debe olvidar que para dar vida al matrimonio debe concurrir un hecho que inicie ostensiblemente la vida conyugal, puesto que con el simple acuerdo en el sentido de querer ser marido y mujer no se contraen nupcias. El hecho consiste, por lo común, en la *deductio* de la esposa *in domum mariti*, acompañada de ceremonias religiosas y festejos sociales; es verdad que ninguna de estas formalidades correspondía a una imperiosa necesidad jurídica, pero entonces era necesario otro hecho; por ejemplo, que los desposados partieran juntos para la residencia del marido, igualmente significativo del cambio de vida. Los textos dicen, por ejemplo, que el matrimonio puede contraerse en ausencia del hombre, por cuanto la mujer puede igualmente ser conducida a su casa, pero que de ningún modo se podría celebrar el matrimonio en ausencia de la esposa; esta última circunstancia basta para excluir, como algún escritor sostiene, que el elemento intencional sea el único requerido.

En cambio, es probable que el principio imperante en materia de posesión, en virtud del cual la desaparición de uno cualquiera de los dos elementos basta para hacerla perder (*supra*, p. 308), haya dejado de aplicarse bien pronto al matrimonio. Ciertamente es que en la antiquísima concepción ya recordada, el alejamiento de la mujer por tres noches consecutivas de la casa del hombre impedía que el matrimonio tomara vida; pero precisamente muy poco después se estableció que la interrupción sirviese para evitar solamente la adquisición de la *manus*, y que el matrimonio, contraído válidamente con el comienzo de la convivencia, sobreviviese al *trinoctium*. En los últimos siglos de la República y bajo el Principado, ni la guerra ni otra causa de ausencia, por prolongada que fuera, hacía cesar el matrimonio; sólo cuando a ella se agregaba la desaparición de la *affectio maritalis*, se lo consideraba disuelto. En definitiva, mientras la máxima *possessio solo animo retinetur* valía en la época clásica para raras hipótesis, el matrimonio subsistía siempre que se mantuviese en ambas partes la *affectio*. Pero la analogía de las dos instituciones resplandece nuevamente en materia de *postliminium* (p. 57); todas las relaciones jurídicas del prisionero de guerra vuelven a tomar vida en el acto de su regreso a la patria, como si nunca se hubiesen extinguido por su caída en esclavitud del enemigo, con excepción del matrimonio y de la posesión, que no reviven sino que sólo pueden restablecerse *ex novo* con la reintegración de los dos elementos constitutivos³.

La demostración más exacta del compromiso en que tuvo origen el matrimonio descrito, está en el hecho de que la posición familiar de la mujer que contrae nupcias permanece invariada: si era *sui iuris*, continúa siendo *caput et finis* de su propia familia;

³ Sobre el tema véase principalmente MANENTI, *Della inopponibilità delle condizioni ai negozi giuridici ed in ispecie delle condizioni apposte al matrimonio*, Siena, 1889, al cual se remonta la doctrina posesoria del matrimonio hoy dominante: con él SCIALOJA, *Corso d'istitut. di dir. rom.*, Roma, 1934, ps. 277 y ss.; BONFANTE, *Ist.*, 10ª edic., ps. 180 y ss., y muchos otros; con particulares aplicaciones, muy discutibles. LEVY, *Hergang der röm. Ehescheidung* [El procedimiento del divorcio romano], Weimar, 1925, ps. 70 y ss., y ALBERTARIO, *Studi di dir. rom.*, 1, ps. 197 y ss. La doctrina ha sido última y brillantemente combatida por VOLTERRA, *La conception du mariage d'après les juristes romains*, Padova, 1940, ps. 33 y ss., y por ORESTANO en la amplia monografía aparecida en el "Bull. Ist. Dir. Rom.", 47, 1940, ps. 154 y ss.; 48, 1941, ps. 88 y ss.; en qué límites sus observaciones me parezcan aceptables resultará a quien confronte las ediciones de este libro desde la 7ª en adelante con las precedentes.

si era *alieni iuris*, la potestad sobre ella la conserva quien era su titular, de manera que nada impide al padre volver a tomar a la hija cuando lo crea conveniente, disolviendo el vínculo matrimonial. Todavía en la época de Antonino Pío no se veía obstáculo para que el suegro intentase contra el yerno los interdictos *de liberis exhibendis* y *ducendis*, salvo la facultad reconocida en casos graves al pretor para denegar el interdicto de su propia autoridad, *ne bene concordantia matrimonia iure patriae potestatis turbentur*⁴.

Tal estructura del matrimonio hace que pueda ser difícil, en ciertas hipótesis, distinguirlo del concubinato; los criterios más significativos están en la consideración y respeto que el marido ha demostrado y demuestra por la mujer, en la admisión de ella en su propia mesa, en su presentación a los familiares, en las ropas que distinguen a las mujeres pertenecientes a la clase social del marido; dado el uso de que la mujer lleve una dote, la existencia o falta de ésta terminó por ser considerada como principal argumento para afirmar o negar el estado matrimonial.

Es singular que ni siquiera el advenimiento y el reconocimiento del cristianismo, cuya influencia fué considerable en tantos aspectos del derecho romano, modificara radicalmente el derecho matrimonial. La concepción del matrimonio como sacramento, que liga indisolublemente a los copartícipes por efecto de la voluntad trascendente que los une, se ha afirmado tarde; y en el Imperio cristiano las ceremonias religiosas pudieron acompañar al matrimonio civil sin alterar su estructura. De cualquier manera, en el derecho justinianeo es visible la tendencia a extraer la prueba de la existencia o de la falta de *affectio maritalis* de la circunstancia de haberse presentado o no las partes a la bendición religiosa (cfr. espec. Nov. 74).

*

* * *

La recíproca capacidad matrimonial (*connubium*) es requisito esencial para un matrimonio válido (*iustum matrimonium* o *iustae*

⁴ Cfr. D. 43, 30, 1 § 5; PAULO, 5, 6, 15; Vat. fr. 116, y sobre estos textos PARTSCH y BETTI, "Il Filangieri", 40, 1915; SOLAZZI, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 34, ps. 1 y ss.; LEVY, *op. cit.*, ps. 144 y ss.; BONFANTE, *Corso*, I, p. 250; ARANGIO-RUIZ, *Persone e famiglia nel diritto dei papiri*, Milano, 1930, ps. 78 y ss.

nuptiae). Para tenerla es necesaria la edad púber (que el hombre sea *pubes* y la mujer *viripotens*), que en los orígenes se establecía quizá, como a principios del Imperio sostenían los sabinianos, mediante una *inspectio corporis*; pero que según la doctrina proculeyana, que triunfó, coincidía para los varones con el cumplimiento del décimocuarto año y para las mujeres con el del décimosegundo. Por análogas razones, el *connubium* falta a los castrados (no ya a los afectados por formas de menos manifiesta impotencia).

El *connubium* falta también a los esclavos, a quien está ya unido en otro matrimonio, y en el derecho justiniano a quien ha hecho voto de castidad o tomado órdenes mayores. En los primeros siglos del Imperio (no sabemos bien en virtud de qué disposición) se prohíbe tomar mujer a los militares en servicio; lo remedian teniendo en su casa concubinas que toman el nombre de *foecariae* o de *hospitae*, pero los nacidos de semejantes uniones no son hijos legítimos ni están sujetos a potestad. Este impedimento fué eliminado por Septimio Severo.

El parentesco origina también una serie de impedimentos. A diferencia de otros derechos de la antigüedad, el derecho romano es, en los orígenes, adverso a las nupcias entre parientes, ya sean agnados o cognados, sin otro límite de grado que el puesto al reconocimiento del parentesco mismo. En la época clásica, la prohibición permanece sin limitaciones en línea recta; en la colateral, la atenuación de la originaria repugnancia y también los intereses particulares de la familia imperial reducen el impedimento a límites más estrechos. Pero las nupcias entre el tío y la sobrina *ex fratre*, admitidas por consideración a Claudio y Agripina, fueron inmediatamente prohibidas otra vez, y no valieron nunca para hacer lícitas por analogía las contraídas entre otros parientes en el mismo grado; en cuanto al matrimonio entre primos, la legislación ofrece toda una serie de alternativas explicables por el conflicto entre las tendencias romana y las orientales, y sólo en el derecho justiniano se sanciona definitivamente la norma favorable⁵. En línea recta, también el parentesco adoptivo es, en cualquier grado, impedimento para las nupcias; en línea colateral, en cambio, el impedimento subsiste solamente entre hermano y hermana adoptivos, y cesa cuando uno de los dos sale mediante emancipa-

⁵ Sobre el tema cfr. ROTONDI, *Scritti giuridici*, I, ps. 216 y ss.

ción de la familia en la que había sido adoptado. Entre afines, el derecho clásico prohíbe las nupcias en la primera línea colateral, es decir entre los que nosotros llamamos cuñados.

Por último, el *connubium* puede faltar también por razones de ciudadanía; se ha señalado ya (ps. 61 y 71) que no existía originariamente sino entre ciudadanos o, mejor aún, entre los pertenecientes a la misma clase; por lo que estaba excluido el matrimonio mixto, no sólo entre romanos y extranjeros, sino también entre patricios y plebeyos. La ley Canuleia, atribuida al año 445 a. C., equiparó desde este punto de vista a los dos órdenes, y sucesivamente el *connubium* fué ampliamente concedido aun fuera de Roma, sea individualmente, sea a ciudades enteras latinas o peregrinas. Conforme a la que se ha visto era su estructura clásica, el matrimonio *sine manu* no modificaba el *status civitatis*: la extranjera que desposa a un romano sigue siendo extranjera, la romana que desposa a un extranjero continúa romana. La consecuencia de la validez del matrimonio se explica sólo respecto al *status* de los hijos: los hijos nacidos de un romano y de una extranjera serán romanos (en cuanto seguirán la condición del padre), si entre los progenitores existía el *connubium*; serán, en cambio, extranjeros (es decir, seguirán la condición de la madre), si no había *connubium* entre los padres, y viceversa si el padre es extranjero y la madre romana. Estas reglas, que no son propias de Roma sino generalmente observadas en el mundo antiguo, sufren agravaciones y alternativas diversas⁶. Una agravación es la relativa a las nupcias entre una romana y el peregrino que no tiene *connubium*: mientras la aplicación de los principios generales haría romanos a los hijos, una ley Minicia (de aproximadamente año 100 a. C.) estableció que naciesen peregrinos. La rigidez de la antigua norma es atenuada (y no sólo en favor de los hijos, sino también de los cónyuges mismos) si se puede establecer que una romana ha desposado a un peregrino o un romano a una peregrina por error sobre el *status* del cónyuge: en tal hipótesis,

⁶ Y ni siquiera éstas son específicamente romanas. El γνώμον del ἰδιος λόγος (cfr. p. 61, nota 14) sienta para el matrimonio de una ἀστὴ (ciudadana de Alejandria) con un egipcio la misma regla de la *lex Minicia* (§ 38), y en los §§ 46 y 47 atestigua también para las ἀστυί una *erroris causae probatio*.

demostrado el error, el cónyuge peregrino adquiere la ciudadanía, y los hijos caen bajo la potestad del padre (*erroris causae probatio*)⁷.

No todas las incapacidades señaladas producen los mismos efectos; por ejemplo, mientras la unión entre libres y esclavos es inexistente para el ordenamiento jurídico, e igualmente quizá la unión incestuosa, el matrimonio entre personas que no tienen *connubium* por razones de nacionalidad es siempre, sin embargo, un *matrimonium*, aunque *iniustum*. Una consecuencia típica, que las fuentes señalan, es que también contra la *iniusta uxor* procedan las sanciones de adulterio, aunque no pueda el cónyuge valerse del procedimiento especial concedido a los maridos como tales⁸; pero además debe admitirse que también semejante *matrimonium iniustum* es impedimento para un ulterior matrimonio, y que, no obstante el cambio en la *civitas* de los esposos, el estado conyugal sea permanente, desde el día en que se inicia la convivencia hasta aquel en que se extingue la *affectio maritalis*⁹.

Por lo menos en sus primeras formulaciones, no anulaban el matrimonio algunas prohibiciones contenidas en leyes y en otras fuentes jurídicas de la época imperial. Así, por la ley *Iulia de adulteriis* (dictada bajo Augusto) se prohibía el matrimonio entre el cónyuge adúltero y el cómplice del adulterio; por la ley *Iulia et Papia Poppaea* estaban prohibidas las segundas nupcias a la liberta que, casada con el patrono, se hubiese divorciado¹⁰, pro-

⁷ No es éste el lugar de insistir sobre otras y más complejas aplicaciones de la *erroris causae probatio*. Si el cónyuge peregrino es un *dediticius*, los hijos adquieren la ciudadanía, pero el *dediticio* permanece tal. Si el error ha recaído no sobre el *status* del cónyuge sino sobre el propio (por ejemplo, un romano ha desposado a una peregrina creyéndose tal a su vez), la *erroris causae probatio* sólo tiene lugar si ha nacido un hijo. Si por último, sin error sobre el *status*, un latino juniano o aeliano (cfr. p. 62) desposa a una romana o latina, la ciudadanía puede ser adquirida por toda la familia y el matrimonio ser declarado *iustum* sólo si un hijo alcanza el año (*anniculi causae probatio*).

⁸ VOLTERRA, *Studi econ.-giur.* Cagliari, 17, 1929, ps. 46 y ss.

⁹ En este orden de ideas, que se ofrece evidente a través de toda la exposición gayana (I, 65 a 96), se explica también la máxima del γνόμεον cit., § 52: Ῥωμαίοις ἐξὸν Αἰγυπτίαν γ[ή]ματι (*Romanis licet Aegyptiam uxorem ducere*). Que no se trata de *matrimonium iustum*, resulta del § 39, donde se atribuye a los hijos la condición de la madre; pero con relación a las poblaciones indígenas podía ser oportuno hacer señalar que este *matrimonium iniustum* era distinto de las uniones con esclavas.

¹⁰ El contenido exacto de las respectivas disposiciones es muy discutido: véase últimamente VOLTERRA, *Studi Riccobono*, 3, ps. 203 y ss.

hibido a los senadores y descendientes de senadores el matrimonio con libertinas¹¹ y a todos los ingenuos el matrimonio con prostitutas o alcahuetas o con mujeres sorprendidas en adulterio, prohibido el matrimonio de personas en edad nupcial (cfr. p. 497) con quien hubiese superado tal edad. Igualmente, los *mandata* imperiales prohibían a los gobernadores de las provincias y al personal de su dependencia desposar mujeres de la provincia administrada, y un senadoconsulto dictado bajo Marco Aurelio y Cómodo prohibió el matrimonio entre la pupila y el tutor que no hubiese presentado aun la rendición de cuentas (como así también sus descendientes, ascendientes y herederos). En el derecho justinianeo se prohíben las nupcias entre raptor y raptada. Las penas son diversas; por ejemplo, en los casos previstos por las leyes matrimoniales augusteas, los contraventores eran considerados como célibes frente a los legados de los extraños, y no podían recibir por testamento uno del otro¹². La nulidad, que habría sido contraria también al principio de la inderogabilidad del derecho civil, fué sancionada para algunos casos con el progreso de los tiempos, a veces por obra de los compiladores de JUSTINIANO.

Otro requisito del matrimonio es el consentimiento de quienes ejercen potestad sobre los contrayentes; es más, para el derecho antiguo el matrimonio depende más de la voluntad de aquéllos que de la de los cónyuges mismos. De allí la consecuencia, sostenida todavía en la época clásica por los juristas más austeros, de que no pueda contraer matrimonio el sometido a potestad de un *furiosus*, por no poder formarse en éste la intención correspondiente. Además, deben consentir en el matrimonio todos los ascendientes intermedios entre el jefe de familia y el esposo, porque de otra manera a la muerte de dicho jefe caerían bajo su potestad descendientes no deseados (*nemini invito suus heres adgnascitur*). Sin embargo, parece que en el mismo derecho clásico el amplio favor del matrimonio hubiera reducido la función de los padres de familia a consentir en la relación que se formaba entre los sometidos a potestad, y que se hubiera

¹¹ Esta norma, como también la otra a que se refiere la nota 10, podrían ser el residuo de un antiguo régimen más severo, que habría prohibido las nupcias entre ingenuos y libertinos.

¹² Cfr. SOLAZZI, "Atti Accad. Sc. Morali e Polit. Napoli", 58, 1938, ps. 269 y ss.

visto también un consentimiento en la falta de oposición; en favor de las hijas se habría admitido también que, en caso de oposición injustificada del padre, pudiese ser requerido *extra ordinem* el magistrado para imponerle el consentimiento. En el derecho justiniano esta norma se extendió en favor de los varones, y la vieja cuestión sobre el consentimiento del *pater familias furiosus* se resolvió admitiéndose que el magistrado consintiera por él¹³.



El principio general de que concurriendo los requisitos necesarios el matrimonio es plenamente libre, fué derogado por el derecho romano en las diversas fases de su desarrollo de distintas maneras: al comienzo del Imperio, conminando a los ciudadanos al matrimonio; en la época cristiana, empeñándose en alejarlos de las segundas nupcias.

El primer orden de disposiciones fué sugerido a Augusto por el propósito de poner un freno a las malas costumbres y a la despoblación, especialmente en las clases dirigentes; por lo menos, desde este segundo punto de vista, no sabemos en qué medida se alcanzó el resultado. Las providencias se tomaron con dos leyes sucesivas, una (*lex Iulia de maritandis ordinibus*) propuesta por Augusto mismo a los comicios, en el año 18 a. C.; la otra (*lex Papia Poppaea nuptialis*) propuesta por sugestión suya por los cónsules del año 9 d. C. Las normas de una y otra, reunidas como en un "texto único" (*lex Iulia et Papia*), fueron luego integradas por varios senadoconsultos (Perniciano, Calvisiano, Claudiano, etc.).

A los hombres desde los 25 hasta los 60 años, a las mujeres desde los 20 hasta los 50, se les impone el deber de contraer matrimonio con persona que esté dentro de los respectivos límites de edad; el matrimonio tardío es considerado, a los efectos especiales de estas leyes, como inexistente. El deber incumbe también

¹³ Sobre el tema cfr. MORIAUD, *Du consentement du père de famille au mariage*, en *Mélanges Girard*, II, ps. 291 y ss.; y para la tesis de la rígida observancia del concepto originario durante toda la época clásica los diversos estudios de SOLAZZI (citados y rebatidos en *Studi in memoria di A. Albertoni*, I, 1933, ps. 31 y ss.).

a los viudos y divorciados, salvo para las mujeres un tiempo intermedio que la ley *Papia Poppaea* fijó definitivamente en dos años después de la muerte del marido, o en dieciocho meses después del divorcio. Se pretende, además (sin que aquí se pueda hablar, naturalmente, de deber jurídico), que las nupcias no sean estériles.

Como sanción del deber matrimonial y como estímulo a la procreación se imponen notables pérdidas patrimoniales a los célibes y orbi (casados sin hijos), y se conceden ventajas a los matrimonios fecundos, sobre todo si la prole es numerosa. Célibes y orbes son principalmente perjudicados en la capacidad para suceder por testamento, en el sentido de que los primeros pueden recibir herencias y legados solamente de los parientes dentro del sexto grado y de que para los segundos se reducen a la mitad los emolumentos que provienen de personas no comprendidas en aquella categoría¹⁴. En las relaciones entre sí, los cónyuges sin hijos pueden recibir solamente una décima parte de la herencia, y además el usufructo de la tercera parte; pero si tienen hijos vivos de otros matrimonios, o si los hijos comunes han vivido por lo menos nueve días, por cada hijo pueden recibir una décima parte más, y en la segunda hipótesis también un tercio del patrimonio en plena propiedad. Otras disposiciones contemplan la dote, que se confisca si es llevada por una mujer de más de cincuenta años a un hombre de menos de sesenta¹⁵; y también establecían, según parece, un impuesto anual del 1% (del patrimonio), que recaía sobre las mujeres núbiles y pudientes¹⁶. Por el contrario, las cuotas o beneficios que los célibes y orbes no pueden recibir (*caduca*), pasan en primer lugar a los *patres* contemplados en el mismo testamento (y solamente a falta de ellos al erario o al fisco); además, para las mujeres que han dado a luz tres veces si ingenuas o cuatro si libertinas, el *ius liberorum* importa, aparte de la plena libertad

¹⁴ De las declaraciones del γνῶμων del ἴδιος λόγος (§§ 30 y 32) resultaría que estas limitaciones alcanzaran sólo a los pertenecientes a las clases pudientes (hombres con un patrimonio de cien mil sestericios, mujeres con uno de cincuenta mil).

¹⁵ En la hipótesis opuesta (del hombre mayor de sesenta años que desposa a una mujer menor de cincuenta), un senadoconsulto Claudiano, citado en el *liber singularis regularum* (16, 3), consideraría válida la constitución de dote. En cambio, el citado γνῶμων (§§ 24 y 25) considera las dos hipótesis de la misma manera.

¹⁶ También este impuesto nos es conocido sólo a través del γνῶμων, § 29.

para disponer por testamento, gravemente limitada para toda otra mujer (cfr. cap. xxv, § 2), también la exención de la tutela agnaticia.

En la época clásica, tales disposiciones fueron con frecuencia derogadas mediante privilegios, especialmente en virtud de concesiones del *ius liberorum* a personas que no tenían hijos o que no los tenían en el número prescrito, o a los célibes directamente. Las incapacidades sucesorias respecto de los extraños fueron abolidas por CONSTANTINO, las recíprocas entre cónyuges sin prole por TEODOSIO II. En el derecho justiniano no quedaba de las leyes matrimoniales de AUGUSTO más que alguna disposición accesorio que formaba parte ocasional de él.

Favorable como era al matrimonio y a la procreación de los hijos, el derecho clásico no podía ser hostil a las segundas nupcias; antes bien, se ha visto que las leyes *Iulia* y *Papia Poppaea* hacían de ellas una obligación, trascurrido cierto intervalo, para las mujeres. Por el contrario, se imponía a la viuda un período de diez meses, dentro del cual las nupcias le estaban prohibidas; no obstante el nombre sentimental de *tempus lugendi*, ese período estaba destinado, como lo pone de manifiesto su medida, a evitar la llamada *turbatio sanguinis*, o sea la incertidumbre sobre la paternidad legítima. Sanción de esta prohibición era la infamia con sus diversas consecuencias (cfr. p. 68). En caso de divorcio no regía una norma análoga, pero el derecho pretorio dispuso los medios necesarios para hacer reconocer la eventual gravidez y la consiguiente paternidad, y para evitar las supresiones y sustituciones de criaturas.

En cambio, el derecho posclásico extiende al caso de divorcio la obligación de no volver a tomar marido dentro de cierto tiempo, eleva el término a un año y castiga a la mujer que deja de cumplir, aparte que con la infamia, con la incapacidad de recibir por testamento y por donación por causa de muerte, como así también con la de recibir sucesiones intestadas de parientes más allá del tercer grado; castiga, en fin, también al segundo marido, prohibiendo que la mujer le lleve en dote o le deje por testamento más de un tercio de los bienes.

En esta época las segundas nupcias son tratadas desfavorablemente aunque sean contraídas por la viuda después de trascurrido el término prescrito, o por el viudo. Pero sólo en el derecho posjus-

tiniano (bizantino) se establecen a este respecto limitaciones propiamente dichas a la capacidad matrimonial; en la época que va desde Teodosio I hasta Justiniano se establecen sólo providencias aptas para impedir que por el matrimonio subsiguiente sufran daños los nacidos de nupcias anteriores. A este fin, todo cuanto el bínubo haya recibido del primer cónyuge, en vida o por causa de muerte y aun a simple título de restitución de la dote, se considera propiedad de los hijos del primer matrimonio, de la cual sólo le corresponde el usufructo, salvo (y no en todas las etapas históricas) la facultad de preferir uno o más entre los hijos mismos; por lo que se refiere a los bienes propios del bínubo, el nuevo cónyuge no puede recibir, ni entre vivos ni por causa de muerte, una cuota superior a la correspondiente al menos favorecido de los hijos de los precedentes matrimonios. Subsiste alguna otra limitación para el caso de que la madre que contrajo segundas nupcias concorra con los otros hijos a la sucesión de uno de los hijos del primer matrimonio.

Ya se ha tratado de los efectos del matrimonio, y en seguida se verá el de mayor relieve, es decir, la legitimidad de los hijos nacidos de él, con la consecuencia de la sujeción a la potestad del padre y de la asunción del *status* que él tenía en el acto de la concepción. Dejando de lado otras consecuencias referentes al derecho penal público, y al delito de adulterio principalmente, convendrá referirse a dos efectos característicos. Uno, que, a partir de Antonino Pío, si la mujer obra contra el marido (en derecho justiniano también en el caso inverso), la condena queda limitada *in id quod facere maritus potest*, es decir, en los límites del activo (es el llamado *beneficium competentiae*). El otro, que en caso de hurto cometido por la mujer en perjuicio del marido, la *actio furti* se le niega a este último, y se la sustituye por una especial *actio rerum amotarum*, también de carácter penal. Esta regla, cuyo origen se remonta hasta el régimen del matrimonio *cum manu*, es tomada como punto de partida por el derecho justiniano para excluir toda acción penal e infamante entre cónyuges, principio

que es referido a una obligación conyugal de mutua *reverentia* (cfr. p. 414, n. 12).

Las consecuencias que surgen del matrimonio con respecto a la sucesión las examinaremos en el cap. xxv, y la prohibición de las donaciones entre cónyuges en el cap. xxvii.

§ 2. LOS ESPONSALES Y LAS "ARRHAE SPONSALICIAE"

En los tiempos en que la mujer era objeto de compraventa (*coemptio matrimonii causa*), era natural que pudiese ser también objeto de obligación entre el jefe de familia originario y aquel bajo cuya potestad debía caer. La obligación se contraía mediante *sponsio* (y éste es, si se quiere, el más antiguo entre los casos verificados de *sponsio*); de aquí el nombre de *sponsalia*, que la promesa de matrimonio conservó aun en la época histórica y conserva todavía entre nosotros. Y era también natural que fuese perseguible, en la época antiquísima a que corresponde la compraventa real de la mujer, la obligación contraída por su *pater familias* originario; la antítesis, que en textos no jurídicos se halla establecida entre esponsales de derecho latino, perseguibles por vía de acción, y esponsales de derecho romano, no perseguibles, puede derivar de una mayor persistencia de la antigua norma en las ciudades del *foedus Latinum*, o quizá también de haberse conservado casualmente el recuerdo de antiguas tradiciones relativas a una u otra ciudad del Lacio.

De todos modos, se abrió camino, con el progreso del tiempo, la idea de que la elección de la mujer para sí o para el sometido a potestad, y el juicio sobre la conveniencia de la colocación de la propia descendiente, debiesen estar libres hasta último momento de todo vínculo. Y desde esta época, demasiado antigua para que se la pueda establecer aproximadamente, la promesa de futuras nupcias no se hizo en formas solemnes, ni creó obligaciones jurídicas.

Pero el derecho posclásico tiende nuevamente a considerar los esponsales como el principio de una fase preparatoria para las nupcias, durante la cual se aplica a los futuros cónyuges buena parte de las normas jurídicas relativas al matrimonio (así, en ma-

teria de adulterio y de impedimentos para otras nupcias)¹⁷. En el mismo orden de ideas, aun dejando formalmente intacto el principio de la libertad del consentimiento, una coacción indirecta se ejerce sobre los esposos mediante las *arrahae sponsaliciae*. Parece que sus orígenes deben buscarse en los países orientales, donde los residuos de la antigua venta de la mujer eran mucho más tenaces que en el mundo grecorromano; allí los esponsales consistían en la dación de una seña de garantía, es decir, en el pago anticipado de una parte del precio prometido a quien ejercía potestad sobre la mujer¹⁸; y, en consecuencia, imperaba la regla de que, rompiéndose el compromiso por culpa del prometido o de su familia, las arras fuesen retenidas por quien las había recibido, y siéndolo por culpa de la prometida o de los suyos, debiesen ser restituídas en el doble.

A través de la legislación de los emperadores posclásicos, de Constantino en adelante, las arras y las reglas a ellas relativas se construyeron sobre el principio romano de los esponsales contraídos mediante declaración no solemne; hasta estuvo en vigor durante cierto período (cuya delimitación es, por lo demás, muy incierta) la norma de la restitución de las arras *in quadruplum*, que dió después lugar a la otra, más de acuerdo con los orígenes, de la retención o restitución *in duplum*. Las penalidades con que de este modo se castiga a los *sponsi* perjuros se evitan sólo cuando el desistimiento es motivado por razones graves, como el mal comportamiento de la prometida o la impotencia del prometido.

La institución descrita representa una derogación del principio clásico de la libertad del matrimonio; sin embargo, en el derecho justiniano se trata de conciliar las reglas opuestas, considerando la pérdida o la devolución de las arras duplicadas como un resarcimiento del daño moral sufrido por la parte no culpable, y manteniendo firme la prohibición que los clásicos habían formulado de la estipulación de una penalidad a cargo de quien violase el compromiso contraído con los esponsales. Pero en la legislación bizantina posterior se vislumbra la tendencia a considerar válida también la cláusula penal, como sustitutiva de las arras, y a identificar los esponsales con el negocio jurídico (dación de arras o estipula-

¹⁷ El esquema de demostración que sobre ellas he dado en las dos primeras ediciones, está hoy absorbido en la vasta investigación de VOLTERRA, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 40, 1932, ps. 87 y ss.

¹⁸ Véanse las arras en la compraventa, sobre la cual cfr. ps. 383 y ss

ción penal) mediante el cual los prometidos se sometían a una responsabilidad por el eventual desistimiento¹⁹.

Para los esponsales deben concurrir los mismos consentimientos requeridos para las nupcias; es más: la voluntad dominante sigue siendo, también aquí, la de los progenitores, y se considera que el descendiente presta su consentimiento toda vez que no se oponga; hasta se ha planteado la cuestión de si para el derecho clásico el consentimiento de la hija no era del todo indiferente. Esto deriva, en parte, de la costumbre, común a los romanos y a otros pueblos, de comprometer en matrimonio también a los niños; en el derecho justinianeo es necesario que ellos hayan cumplido por lo menos los siete años, y es dudoso que ésta haya sido la más precisa determinación de un uso de razón requerido también por los clásicos o si se trata, en cambio, del límite puesto por primera vez a la completa libertad que los clásicos habrían dejado a los progenitores²⁰.

§ 3. DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO. EL DIVORCIO

Después de cuanto se ha dicho más arriba (ps. 489 y ss.), está claro que la muerte de un cónyuge (la cual, según los principios cristianos y las ideas dominantes en nuestra civilización, es la única causa de disolución del matrimonio) no podía ser para el derecho romano sino la causa estadísticamente dominante. A su lado, tienen igual importancia jurídica las causas de disolución que se vinculan con la desaparición de la recíproca capacidad matrimonial, o de la voluntad de vivir recíprocamente como marido y mujer (*affectio maritalis*; cfr. ps. 489 y ss.).

Pero respecto de la primera serie de causas corresponde distinguir según el grado de la incapacidad, y, en consecuencia, de la invalidez que viene a afectar al matrimonio (cfr. ps. 495 y ss.). Puesto que entre esclavos no se concibe relación matrimonial, las causas productoras de *capitis deminutio maxima* (pérdida del sta-

¹⁹ Sobre el tema cfr. KOSCHAKER, "Rev. Fundac. Savigny", 33, 1912, ps. 383 y ss.; VOLTERRA, "Riv. Ital. Sc. Giur.", nueva serie, 2-4, 1926-1929, y "Stud. et Docum.", 3, 1937, ps. 135 y ss.

²⁰ En este último sentido SOLAZZI, en "Atti Acc. Torino", 51, 1916, p. 761 en nota, con una exégesis de D. 23, 1, 14, que parece altamente persuasiva. A SOLAZZI pertenece también la duda sobre la necesidad del consentimiento de la hija en los esponsales.

tus libertatis) disuelven siempre el matrimonio²¹. De producirse, en cambio, una *capitis deminutio media* (que priva a uno de los cónyuges del *status civitatis*), el *matrimonium* se hace *iniustum*, y por consiguiente los hijos concebidos con posterioridad no caen bajo la potestad del padre; pero permanece válido *iure gentium*, y en caso de readquisición de la ciudadanía es restituído en su plena validez de derecho civil²². En cuanto a la *capitis deminutio minima*, que cambia el *status familiae*, debió ser causa de disolución solamente en el matrimonio *cum manu*, o más bien cuando no se podía contraer matrimonio sin *manus*. Pero después del advenimiento del matrimonio *sine manu*, la exclusión de todo parentesco agnaticio entre los cónyuges hizo que la *capitis deminutio minima* no tuviese ya influencia, y que aunque por vía excepcional se hubiese verificado la *conventio in manum*, la salida de uno de los cónyuges de la familia extinguiese sólo la *manus*, sin disolver el matrimonio.

En el derecho clásico, el matrimonio se disuelve también si por vía de adopción los cónyuges vienen a hallarse en una relación de parentesco que resulte obstáculo para las nupcias (*incestum superveniens*), como si el suegro adopta al yerno o a la nuera. La regla se mantiene en el derecho justiniano sólo para la *adoptio plena*, no ya para la *minus plena* (cfr. p. 528)²³.

En fin, el matrimonio puede disolverse por voluntad de ambos cónyuges o de uno de ellos. Para el antiguo matrimonio *cum manu* es necesario distinguir entre la *confarreatio*, por una parte, y la *coemptio* (con el *usus* que le está equiparado), por otra. El

²¹ Por derecho clásico, el matrimonio no es ni siquiera restablecido por el *postliminium* (p. 491). Por derecho justiniano, en cambio, el matrimonio se entiende disuelto solamente si por cinco años no se ha tenido noticia del *captivus*; el cónyuge que pasase a segundas nupcias antes del vencimiento de este término, quedaría sometido, en caso de regreso del ausente, a las penas del divorcio ilícito (v. *infra*, p. 508).

²² Esto no impide que en derecho clásico se hable, a este propósito, de una *solutio* o *dissolutio matrimonii*; así, en particular cuando, derivando la pérdida de la ciudadanía de una pena (*aquae et ignis interdictio*), el *capite minutus* se transforma en apátrida. Que la solución diversa adoptada en el *Corpus iuris* para la deportación (*matrimonium non dissolvi*) sea justiniana, está confirmado ahora por BONFANTE, Corso, I, p. 243 y *passim*.

²³ En cambio, si se caía en una de las prohibiciones de las leyes augusteas (por ejemplo, si el marido de una libertina llegaba a ser senador), nacía solamente la obligación del divorcio, con las sanciones indicadas en la p. 496.

matrimonio celebrado mediante *confarreatio* no puede disolverse sino con una ceremonia religiosa correspondiente llamada *diffarreatio*; la *manus* adquirida mediante *coemptio* es renunciable, sea mediante *remancipatio* al padre de familia originario, sea mediante *emancipatio* (p. 531). Lo que equivale a decir que en la época primitiva la voluntad de los cónyuges como tales en el sentido de permanecer unidos en matrimonio, carecía de eficacia frente a la de los respectivos padres.

Para el matrimonio libre (*sine manu*), así como el acto solemne que crea o transmite la potestad es sustituido por el establecimiento de la unión conyugal, también el acto solemne que destruye la potestad es sustituido por la desaparición de la *affectio maritalis*; el nombre *divortium* describe plásticamente el hecho de que los cónyuges, después de haber recorrido juntos un trecho de la existencia, se alejan por distintas vías (*divertunt*). Ello no impide, por lo menos en una primera época, que la voluntad de quienes ejercían potestad sobre los cónyuges o del tutor sobre la mujer hubiera continuado predominando sobre la de los cónyuges mismos; pero el proceso histórico que lleva al predominio de la voluntad de los cónyuges, se desarrolla aquí más rápidamente que en materia de consentimiento para las nupcias. De cualquier manera, sólo en la época posclásica la voluntad de los cónyuges, aun *alieni iuris*, se hace del todo independiente.

El divorcio²⁴ se produce, pues, toda vez que en ambos cónyuges o en uno de ellos desaparece la *affectio maritalis*. En la época republicana, este estado de ánimo encontraba su expresión en la separación material, acompañada por lo común con la declaración de uno u otro de los cónyuges de querer romper con ella el vínculo conyugal (*repudium*). La falta de toda formalidad en tal declaración daba lugar a cuestiones complejas, y hasta ponía en peligro el principio fundamental de la monogamia, pudiéndose con algún artificio interpretar el segundo matrimonio como señal de cesación de la *affectio* correspondiente al primero²⁵; pero no parece que el derecho clásico haya resuelto el problema con una norma general. Sin embargo, para algunas hipótesis especiales, quizá sólo para el caso en que la inexistencia del divorcio fuese presu-

²⁴ Sobre las formas cfr. LEVY, op. cit. en la p. 491, nota 3; SOLAZZI, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 34, 1925, ps. 312 y ss.

²⁵ Cfr. el caso recordado por CICERÓN, *De orat.*, 1, 40, 183.

puesto de la aplicación de sanciones penales, la *lex Iulia de adulteriis* (año 18 a. C.) remitía, confirmando, al uso ya impuesto de documentar el divorcio con una de las acostumbradas *testationes* que llevara los sellos de siete testigos. Este ocasional reconocimiento legislativo sirvió para divulgar en todos los casos de divorcio el empleo del mismo medio. En el derecho justinianeo, el *libelus repudii* con las indicadas formalidades es necesario para la validez del divorcio²⁶.

En los orígenes, el divorcio era visto desfavorablemente por la costumbre; el repudio no justificado por graves razones (por ejemplo, el adulterio de la mujer o el hecho de que hubiera bebido vino) fué castigado por el *fas* con la consagración de una parte de los bienes del repudiante a Ceres, después por los censores con su *nota* (cfr. ps. 67 y ss.).

La degeneración de las costumbres, rápidamente desarrollada en los últimos siglos antes de Cristo, hizo extraordinariamente frecuentes los divorcios, manteniéndose igualmente durante toda la época clásica. Pero también respecto de este asunto es necesario cuidarse de atribuir a todas las partes del mundo romano y a todas las clases sociales fenómenos que todavía hoy, en los países en que se admite el divorcio, se producen con preferencia entre la gente rica y ociosa; en las clases medias y en provincia, el divorcio debió ser menos frecuente, y esta deducción parece confirmada por los papiros de Egipto. La mayor cohesión familiar mantenida en el mundo provincial, y la influencia del cristianismo (el cual, aun sin ver todavía en el matrimonio una institución divina, consideró, sin embargo, a la pluralidad de matrimonios sucesivos como

²⁶ En la descripción de los diversos tipos de disolución voluntaria del matrimonio, se han tenido presentes los dos casos extremos: matrimonio *cum manu* del tiempo en que era ésta la única unión conyugal válida, y matrimonio *sine manu*. Pero hay una tercera hipótesis del matrimonio *cum manu* contraído en el tiempo en que la *manus* ya no era esencial; y aquí podrían surgir problemas delicados. Alguien podría querer renunciar a la *manus* conservando firme el matrimonio; resultado fácil de alcanzar celebrando una *emancipatio* para continuar tratando a la mujer como tal. Teóricamente es posible también que, desaparecida la *affectio maritalis* y verificado, en consecuencia, el divorcio, subsista la *manus*. Esta consecuencia repugnante pudo en el origen evitarla sólo quien tuviera la potestad, haciendo seguir al *repudium* la *emancipatio*; pero posteriormente se le dió a la mujer el medio de constreñir al que tuviera la potestad a emanciparla (probablemente mediante recurso a la autoridad por vía de *cognitio extra ordinem*).

señal de pecaminosa incontinencia), hicieron que el divorcio estuviese rodeado, en el derecho posclásico, de reservas y precauciones. La materia fué nuevamente sometida a examen varias veces en el tiempo transcurrido desde Constantino hasta Justiniano (cfr. las constituciones 7-12 C. 5, 17); pero tuvo una regulación definitiva en las Novelas 22 (año 535) y 117 (año 542). En esencia, ninguna de estas disposiciones abre una brecha en el principio fundamental de la disolubilidad del vínculo nupcial, toda vez que desaparece, en ambas partes o en una sola de ellas, la *affectio maritalis*; aun en el último derecho justiniano, el capricho de un cónyuge, con tal que sea declarado en el *libellus repudii*, disuelve el matrimonio. Pero, mientras en ciertos casos el divorcio se produce con el pleno favor del ordenamiento jurídico, en otros tal ordenamiento le es hostil, y demuestra esta hostilidad conminando penalidades contra los que se divorcian.

En cambio, son favorecidos por el ordenamiento jurídico los divorcios *bona gratia* y *ex iusta causa*. *Bona gratia* es el divorcio dispuesto por razones que no son moralmente imputables a ninguno de los cónyuges, pero que hacen imposible la consecución de los fines normales del matrimonio; tales el voto de castidad, la impotencia (puesta de manifiesto por la falta de unión sexual dentro de los tres años del matrimonio) y la presunción de muerte que resulte de la circunstancia de no haberse tenido noticias, por cinco años, del prisionero o desaparecido en una guerra. En cambio, es *ex iusta causa* el repudio por hecho imputable al repudiado; así, por parte de la mujer, el adulterio, el haber ido a banquetes o a los baños con extraños o a habitar fuera de la casa con personas a quienes no estuviese ligada por vínculos de parentesco, o haber frecuentado espectáculos sin consentimiento del marido; por parte del hombre, haber intentado prostituir a la mujer, tener una concubina, la falsa acusación de adulterio; por parte de ambos, haber tramado insidias contra la vida del cónyuge o haberse despreocupado por las tramadas por otros, haber conjurado o favorecido conjuración contra el emperador o la emperatriz. En las hipótesis de divorcio *ex iusta causa*, el repudiado incurre en sanciones pecuniarias, como la pérdida de la dote o de la donación nupcial o —a falta de ellas— de una cuarta parte del patrimonio, y puede ser forzado a recluirse en un convento, aparte de las penas públicas a aplicarse cuando la justa causa de divorcio constituya de por sí un delito.

Las mismas penas eran conminadas por las Novelas citadas contra los que se divorciaban caprichosamente, es decir, contra el repudiante en el *repudium sine ulla causa* y contra ambos cónyuges en el *divortium communi consensu*. Pero mientras para el primer caso las normas se aplicaron a conciencia, para el segundo encontraron tal hostilidad en la práctica que ya en el año 566 Justino II, sobrino y sucesor de Justiniano, debió declarar exento de pena el divorcio *communi consensu*. Ni la repetida conminación de penitencias canónicas sirvió en los siglos que siguieron inmediatamente para encerrar dentro de más estrechos límites el arbitrio de los cónyuges.

§ 4. RELACIONES PATRIMONIALES ENTRE CÓNYUGES. LA DOTE Y LA DONACIÓN "PROPTER NUPTIAS"

La *conventio in manum* y la sucesión universal. Orígenes de la dote y su empleo también en el matrimonio *sine manu*. La propiedad del marido sobre la dote y los límites al derecho de disponer de ella. La restitución de la dote: *actio ex stipulatu* y *actio rei uxoriae*. Los *παράδογμα*. La institución oriental de la *donatio propter nuptias* y su recepción en el derecho romano posclásico. La práctica de la comunión de los bienes en los documentos egipcios de la época justiniana.

El más antiguo régimen del matrimonio romano, y especialmente la institución característica de la *coemptio*, muestra que también en Roma hubo un período primitivo en el cual la adquisición de una mujer en matrimonio era considerada como una mera ventaja para la familia que la recibía, ventaja tal que debía comprarse con dinero; es evidente que no podía surgir en este período la costumbre de que la mujer o sus parientes entregaran bienes en provecho de la nueva familia. Sin embargo, había un caso en el cual la compra de la mujer llevaba consigo una adquisición patrimonial; era el de la mujer *sui iuris*; cuya *conventio in manum* hacía que el marido o quien ejerciese potestad sobre él le sucediese en todas las relaciones jurídicas transmisibles²⁷. Cuando la idea de la mujer vendida y comprada como instrumento de procreación cedió su lugar a la de cooperación de los cónyuges en la vida eco-

²⁷ Esto ha ocurrido, naturalmente, desde que hubo mujeres *sui iuris*. Sobre las dudas que surgen acerca de la situación primitiva de la mujer en Roma, cfr. *infra*, ps. 565 y ss.

nómica y moral de la familia, y la *coemptio* se redujo a una venta imaginaria, se difundió también la costumbre de que la mujer *alieni iuris*, que en virtud de la *conventio in manum* perdía toda expectativa de sucesión respecto de la familia de que se separaba, entrase en la nueva acompañada por cierta cantidad de bienes, que por una parte la indemnizase de la expectativa perdida y por otra representase su contribución y la de los suyos en los gastos de la vida conyugal. A estos bienes (que en los orígenes debemos suponer entregados o prometidos, en el acto de la *coemptio*, por el *pater familias* originario a quien adquiría la *manus*) se dió el nombre de dote (*dos*). Nacida, pues, en el matrimonio *cum manu*, la dote pasó al *sine manu* con el fin de ayudar al marido a soportar las cargas del matrimonio (*ad onera matrimonii ferenda*); los derechos sucesorios de la mujer respecto a su familia permanecían intactos, pero por costumbre el jefe de familia que había dotado a la hija, la excluía en su testamento de la herencia en provecho de los otros descendientes²⁸, reproduciendo así la situación que hemos visto en el régimen de la *coemptio*. La dote puede ahora ser constituida, además que por el *pater familias*, también por la mujer *sui iuris* (quien puede comprender en ella todos sus bienes, aunque más a menudo conserva una parte de ellos) o por extraños; la obligación social de dotar (deber tan profundamente arraigado en la conciencia social como para que su incumplimiento fuese considerado argumento decisivo para distinguir el matrimonio del concubinato), se transforma en jurídica en el mundo posclásico²⁹, y mientras que primeramente pesaba sólo sobre el ascendiente paterno, ahora se extiende, de conformidad con la nueva estructura económica de la familia, también a la madre pudiente.

La constitución de la dote no es, en la concepción romana, un negocio jurídico en sí, sino un fin económico que puede lograrse con diversos tipos de negocios. De estos tipos, sólo uno está específicamente destinado al fin; y es la *dictio dotis*, contrato verbal que se perfecciona mediante una declaración solemne del constituyente, recibida por el marido o por quien tiene potestad sobre él; este modo de constitución sólo puede practicarlo la mujer, el ascendiente varón o el deudor de ella (cfr. p. 358). Al lado de la *dictio*, un

²⁸ Cfr. VON WOESS, *Das römische Erbrecht und die Erbanwärter* [El derecho hereditario romano y los sucesibles], Berlín, 1911, ps. 89 y ss.

²⁹ Cfr. CASTELLI, *Scr. giur.*, ps. 129 y ss.

célebre pasaje del *liber singularis regularum*³⁰ indica los otros dos medios empleados al efecto: la *promissio dotis*, hecha mediante la acostumbrada estipulación, y la *datio dotis*, que consiste en realizar simplemente los actos destinados a hacer al marido titular de los bienes que se quieren constituir en dote, independientemente de toda obligación precedente. A título de *datio*, o en ejecución de la *dictio* o de la *promissio*, se hace la mancipación de fundos y de esclavos, la tradición de cosas *nec mancipi*, la delegación de un crédito (p. 448), la *acceptilatio* de una deuda (p. 441), etc.³¹.

En el derecho justiniano, la dote se puede prometer también mediante convención no solemne, y es admitida asimismo la reconstitución tácita, en un segundo matrimonio, de la dote ya constituida en favor del primer marido y luego restituída a la mujer; pero en la práctica se prefiere, según la conocida tendencia de la época, el documento (*instrumentum dotale*).

La dote puede ser constituida tanto antes del matrimonio como al comienzo de la vida conyugal o *durante matrimonio* (solamente la forma de la *dictio* está excluida después de las nupcias): en la primera hipótesis se entiende que la promesa o la transferencia de los bienes tiene eficacia definitiva sólo cuando el matrimonio se realiza, considerándose este acontecimiento como condición suspensiva si ha tenido lugar una promesa, resolutoria en caso de efectiva dación.

Según la persona del constituyente, la dote se distingue en *profecticia* y *adventicia*; en general, la primera proviene del ascendiente que tiene la potestad sobre la mujer; la segunda, de cualquier otro, comprendida la mujer misma. El derecho clásico revela una tendencia a ampliar la definición de la *dos profecticia*, para comprender en ella también a la constituida por el progenitor que no tiene ya en potestad a la hija por haberla emancipado o dado en adopción; pero el derecho justiniano vuelve a la rigurosa distinción primitiva.

Destinada a sostener las cargas del matrimonio, la dote cae bajo el señorío del marido o de quien ejerce potestad sobre él; en la hipótesis más común, en que son objeto de la dote cosas corporales, el jefe de familia es propietario de ellas; lo que se en-

³⁰ 6, 1: "Dos aut datur aut dicitur aut promittitur".

³¹ Cfr. LAURIA, "Atti Accad. Napoli", 57, 1937, ps. 235 y ss.

tiende, desde el principio, en el sentido de una plena y perpetua disponibilidad. Pero todo el desarrollo de la institución, en la legislación y en la costumbre, se orienta en el sentido de reservar la dote al marido aunque sea hijo de familia, de restringir en interés de la mujer y de los hijos su facultad de disposición, de obligarlo a la restitución después de la disolución del matrimonio. Y al término de la evolución, acelerada en la época posclásica por la influencia de concepciones jurídicas no romanas, la afirmación de la propiedad del marido queda como meramente teórica; sustancialmente su poder no es distinto de ese usufructo legal que en el derecho justinianeo corresponde al padre sobre los bienes de los hijos (cfr. *infra*, p. 538)³².

Ante todo, se trató de impedir esa confusión con el resto del patrimonio del jefe de familia, que se producía, en rigor, cuando el marido era hijo de familia; en efecto, los padres acostumbraron constituir en peculio a los descendientes las dotes constituídas por las respectivas mujeres y a hacerlas objeto de prelegado en los testamentos; y el uso fué reforzado por la regla jurisprudencial de que, aun ante el silencio del testamento, se procediese como si la dote hubiera sido prelegada. Más grave era el peligro de la disipación de los bienes dotales por obra del marido. Con relación a los inmuebles lo obvió la llamada *lex Iulia de fundo dotali*, nombre usualmente dado a un capítulo de la ley augustea *de adulteriis*, que dispuso que no pudieran enajenarse los fundos itálicos entregados en dote, ni constituirse sobre ellos *iura in re aliena*, sino con el consentimiento de la mujer; en el derecho posclásico, la adaptación de la propiedad provincial a la civil (cfr. p. 206) hizo que la norma se extendiese a toda la propiedad inmobiliaria, y JUSTINIANO la agravó declarando ineficaz también el consentimiento de la mujer. Sin embargo, parece que por lo menos en derecho clásico, la enajenación en que se hubiese tras-

³² De este resultado el derecho clásico está todavía bien lejos; por lo que son probablemente interpoladas aquellas declaraciones, contenidas en el Digesto, en las cuales la dote es considerada *patrimonium mulieris*, y las soluciones prácticas inspiradas en el mismo criterio. Algún esbozo de demostración fué hecho por mí en la primera edición; ahora la tesis está ampliamente probada por ALBERTARIO, "Rend. Ist. Lomb.", 58, 1925, ps. 809 y ss. (= *Studi*, I, ps. 295 y ss.). Muy interesante, para el estudio de la posición jurídica de la mujer respecto de la dote, es la investigación de WOLFF, "Rev. Fundac. Savigny", 53, 1933, ps. 297 y ss., aunque demasiado conservadora con respecto a algún texto.

gredido la prohibición no fuese nula, sino que sólo estaba sujeta a revocación a instancia de la mujer. En cuanto a los muebles, el interés de la mujer y de los terceros fué, a menudo, garantizado mediante la valuación (*aestimatio*) de los objetos dotalés particulares, que podía hacerse no sólo *taxationis causa*, con el fin de fijar por adelantado el monto del resarcimiento debido por el marido en caso de pérdida que le fuera imputable, sino también *venditionis causa*, en el sentido de que el marido debiese luego responder no por los objetos recibidos sino por su equivalente en dinero.

Mucho más interesante es el desarrollo que condujo a la obligación general de restitución a la disolución del matrimonio. Al principio, tal obligación nacía solamente si al negocio constitutivo de la dote se le agregaba una estipulación mediante la cual el marido se comprometía a restituirla; surgía, en tal caso, en favor del constituyente, como de cualquier otro acreedor por estipulación, una *actio ex stipulatu*, que en tiempo oportuno podían hacerla valer también, eventualmente, los herederos del constituyente; la dote tomaba entonces el nombre de *recepticia*. A esta hipótesis se aproximó mucho más tarde la del pacto (no formal) de restitución, concluido entre las partes en el momento de la *datio dotis*; el derecho posclásico ofrece en estas circunstancias al constituyente la acción que tutela los contratos innominados (*actio praescriptis verbis*; cfr. ps. 354 y ss.). Pero ya en los últimos siglos de la República el concepto de que la dote se hace propia del marido solamente en cuanto pesan sobre él las cargas del matrimonio llevó a reconocer a la mujer, cuando el matrimonio se disolviese por divorcio, un derecho a la restitución, y con este fin se creó (según parece, por interpretación jurisprudencial, y en época anterior al más amplio desarrollo del Edicto pretorio) una acción *rei uxoriae*, cuyo juez debía estimar caso por caso *quod melius aequius erit uxori a marito reddi* (acción *in bonum et aequum concepta*); por ello, tal acción fué equiparada con mucha frecuencia a los *bonae fidei iudicia*, y hasta bajo ciertos aspectos incluida en esta categoría³³. La acción corresponde a la mujer mis-

³³ Contra esta inclusión, con argumentaciones muy finas pero no siempre resistentes, BRONDI, *Iud. bonae fidei*, I, ps. 78 y ss. Parece, de todos modos, que deba excluirse que la *actio rei uxoriae* haya sido nunca, como muchos consideran, penal; el tiempo trascurrido entre los orígenes de la acción y la época de Cicerón es demasiado breve, como para que en

ma si es *sui iuris*, y siempre que la dote sea *adventicia* o el padre haya muerto; de otra manera, es requerida por el padre, pero con el consentimiento de la hija (*adiuncta filiae persona*). El derecho a la restitución es personalísimo y la acción no puede, en consecuencia, ser intentada por los herederos de la mujer.

La referida cláusula de la fórmula, cuya aplicación fué objeto de normas especiales en la legislación augustea, hizo que la restitución pudiese ser impuesta en todo o en parte, en mayor o en menor medida, según las circunstancias; se tuvieron en cuenta las condiciones económicas del marido, evitando que la condena superase su patrimonio activo (el llamado *beneficium competentiae*), y en todo caso se lo autorizó para retener determinadas cuotas, sea por la existencia de hijos (*retentio propter liberos*), sea para castigar la mala conducta de la mujer (*retentio propter mores, graviore*s [adulterio] o *leviores*), sea por gastos necesarios o útiles (estos últimos, según algunos juristas, sólo si fueron consentidos por la mujer) (*retentio propter impensas*), sea por donaciones que se le hicieron en contravención de la prohibición de las donaciones entre cónyuges (*retentio propter res donatas*), sea, por último, por indebidas sustracciones por parte de la mujer de los bienes maritales (*retentio propter res amotas*)²⁴.

La restitución, que debe ser inmediata para las cosas no fungibles que no han sido estimadas, se hace, en cambio, en tres cuotas anuales (*annua, bima, trima die*) si se trata de dinero o de otras cosas fungibles o de dos *aestimata*.

Mientras de esta manera se precisaba el contenido de la *actio rei uxoriae*, se ampliaba su aplicación. Surgida sólo para la hi-

él se pueda suponer tan extraviado el primitivo concepto, que permita aproximar a los juicios de buena fe un medio judicial nacido como penal. La intrasmisibilidad activa se explica con un criterio totalmente diverso; el de que las razones de equidad por las cuales la dote era restituida, no militaban en favor de otros que no fueran la mujer misma. Las máximas aquí sentadas están confirmadas por la investigación de Grosso, "Riv. Ital. Sc. Giur.", nueva serie, 3, 1928, ps. 39 y ss.; pero me causan cierta perplejidad, sobre todo por lo que respecta a la fórmula, las observaciones de LAURIA, loc. cit., ps. 246 y ss.

²⁴ En caso de dos *recepticia*, algunas de estas contrapretensiones del marido, no siendo oponibles a la acción *ex stipulatu*, se hacían valer con acciones especiales, como la *actio rerum amotarum* (*supra*, p. 500) y el misterioso *iudicium de moribus* (sobre el cual cfr. últimamente BONFANTE, Corso, I, ps. 345 y ss.).

pótesis del divorcio y como dirigida exclusivamente contra el marido, se la aplicó también al matrimonio disuelto por muerte del marido mismo; intentándose contra los herederos de éste; y para la *dos profecticia* se admitió que el *pater familias* pudiese obrar *rei uxoriae* también después de la muerte de la hija.

A esta reglamentación minuciosa y prudente, que socavaba pero no subvertía el principio según el cual la dote era propiedad del marido, se contrapuso en la época posclásica la concepción de las provincias helenísticas según la cual la dote era propiedad de la mujer, correspondiéndole al marido solamente un derecho de administración y percepción de los frutos *durante matrimonio*. Dentro de tal orden de ideas, la dote debía ser restituida siempre, de cualquier manera que el matrimonio se disolviese, y la acción correspondía en todo caso también a los herederos de la mujer; desapareció así toda razón para distinguir de los otros casos aquel en que la restitución había sido estipulada (*dos recepticia*). La acción para la restitución de la dote es, para JUSTINIANO, siempre la misma: lleva usualmente el nombre de *actio de dote*, pero en algún texto fundamental se le atribuye aquel de entre los dos nombres antiguos que menos le convendría, *actio ex stipulatu* (cosa muy extraña, dado que la restitución no es ya objeto de estipulación). La acción, por lo demás, está en antítesis con la homónima que aun en el derecho justiniano nace de la estipulación, de buena fe, en el sentido de que el juez puede tomar en cuenta las contrapretensiones del demandado y conciliar equitativamente los intereses opuestos. De la regulación de la antigua *actio rei uxoriae* sobrevive en la nueva el *beneficium competentiae*; en cambio, son abolidas las *retentiones*, cuyo resultado económico puede ser normalmente alcanzado con acciones correspondientes al marido o a los herederos del marido contra la mujer o sus herederos, o bien, a través de otras normas de derecho, sin embarrasar el inevitable retorno de la dote a quien es ahora económicamente su verdadera titular³⁵. La restitución debe hacerse en

³⁵ A la función de la *retentio propter res amotas* sirve la *actio rerum amotarum*; a la de la *retentio propter impensas* la *actio negotiorum gestorum*; a la de la *retentio propter res donatas* la *vindicatio* o la *condictio* de las cosas donadas contra la prohibición; a la de la *retentio propter mores* las penalidades conminadas contra el repudiado *ex iusta causa* (cfr. p. 505); a la de la *retentio propter liberos* el nuevo régimen de la sucesión necesaria de los descendientes frente a ambos progenitores (cap. xxv, § 4).

general inmediatamente para las cosas fungibles no estimadas, y para las cosas no fungibles o *aestimatae* dentro del año.

El refuerzo de los derechos de la mujer sobre la dote se manifiesta también en la *rei vindicatio utilis* que el derecho posclásico le concede para perseguir las cosas dotales contra el marido o contra cualquier tercero, y en la hipoteca general que en la misma época le es atribuida sobre los bienes del marido, en garantía de la buena administración y de la exacta restitución.

*
* *

Los bienes de la mujer *sui iuris* no constituídos en dote continúan, en el matrimonio *sine manu*, en su propiedad, y puede disponer de ellos en los límites y formas permitidos por los principios generales. En algún texto justiniano, y especialmente en la Novela 97 c. 5, al conjunto de los bienes no constituídos en dote se le da el nombre de *παράφερνα* (de allí, la denominación aun corriente de bienes parafernales); pero en los papiros greco-egipcios, donde se nos ofrece en su mayor desarrollo, la institución de los *παράφερνα* representa más bien un segundo aporte de la mujer, que se agrega a la dote y comprende sus objetos de uso personal o una modesta suma destinada a costear su adorno; de estos bienes, que entran en casa del marido, él firma un inventario para garantizar la restitución a la disolución del matrimonio. En las provincias occidentales, el aporte análogo de la mujer solía llamarse *peculium*, y no pasaba a la propiedad ni posesión del marido, quien era considerado simplemente su depositario³⁶.

*
* *

El extremo cuidado con que el derecho justiniano regula la institución de la dote, y el hecho de que esta regulación no sea

³⁶ Cfr. CASTELLI, *I παράφερνα nei papiri greco-egizii e nelle fonti romane* (= *Scr. giur.*, ps. 1 y ss.), con el cual disiento sólo en la valoración de los textos justinianos.

prácticamente muy distinta a la del derecho clásico, hace poco visible un desarrollo que, partiendo de leyes y costumbres orientales, ha transformado profundamente el régimen de las relaciones patrimoniales entre cónyuges. La institución sobre la cual se afirma la reforma, y que tiene en la compilación (como sucede con frecuencia) un lugar inadecuado a su importancia práctica, es la donación del marido o de otro por cuenta suya a la mujer, a la que antes de JUSTINIANO se daba el nombre de *donatio ante nuptias*, y después el de *donatio propter nuptias*.

Los precedentes de la donación en examen son múltiples. Los regalos del novio durante el compromiso o en el acto de las nupcias, que eran en Occidente simples testimonios de afecto bajo la forma de donaciones inmediatas (obsequios manuales), asumían en otros lugares (especialmente, por lo que nos consta, en el mundo asirio-babilónico y en el antiguo Egipto) la característica de *pretium pudicitiae*, o bien la función de garantizar a la mujer una parte de los bienes del marido en caso de viudez, o, en fin, la de preordenar una pena para la hipótesis de divorcio causado por el marido o injustamente querido por él. De aquí también la tendencia, observada entre algunos pueblos, a establecer una proporción entre la donación nupcial y la dote (por lo general según la relación de uno a dos) y a comprender dote y donación en un acto escrito de matrimonio, que dispone tanto sobre los derechos y obligaciones personales de los cónyuges como respecto a su recíproca posición patrimonial durante el tiempo de la convivencia conyugal y después de ella. Tendencia ésta que en Egipto parecería haberse ocultado sabiamente, bajo la dominación griega y en los primeros tiempos de la romana, o haciendo que aquella donación figurase como dote constituida por la mujer, o fundiéndola con la verdadera dote en una masa única, o, en fin, callando completamente, pero poniendo a cargo del marido la obligación de restituir en caso de divorcio, además de la dote, una multa equivalente a la mitad de ella (*ἡμιόλιον*), bajo la cual se disimulaba la donación³⁷.

³⁷ Véase la hipótesis de FRESE, *Aus dem gräko-ägypt. Rechtsleben* [De la vida jurídica greco-egipcia], 1909, ps. 45 y ss., que mira con buenos ojos MITTELS, *Grundzüge der Papyrskunde* [Lineamientos de papirología], II, p. 225; óptimas observaciones de derecho comparado en HOLL-DACK, *Zur Geschichte der d. a. n. und der d.* [Sobre la historia de la don. ante n. y de la dote], en los *Festgabe für Güterbock*, 1909, ps. 505 y ss.

A las concepciones señaladas, y quizá también a otras más o menos afines y mal conocidas, se fué adaptando fatigosamente el derecho romano a partir de la época de Constantino; pero la diversidad de las costumbres locales produjo una serie de disposiciones algo heterogéneas. Un punto de vista en el cual la legislación imperial parece mantenerse firme, es el de la conexión entre donación nupcial y dote, en el sentido de que, así como la segunda es restituida a la mujer en caso de prefallecimiento del marido, la primera es restituida al marido en caso de prefallecimiento de la mujer. Pero mientras la dote, destinada *ad onera matrimonii ferenda*, es normalmente entregada en el acto del matrimonio, la donación nupcial revela su fin de garantir el porvenir de la mujer en el hecho de que a menudo consiste, más que en una entrega actual del marido, en una deuda que él contrae para la fecha de la disolución del matrimonio; equivale así en la hipótesis de muerte a un pacto sucesorio, y en la de divorcio a una penalidad para el marido repudiante. Más tarde, primero sólo para la hipótesis de las segundas nupcias y después con carácter general, se dispuso que a la muerte del marido la mujer adquiriese la propiedad de la donación nupcial solamente si del matrimonio no hubieran nacido hijos, y que en el caso opuesto adquiriese solamente el usufructo, correspondiendo la propiedad a los hijos.

Bajo este aspecto, donación y dote pueden considerarse como instituciones concurrentes al fin único de garantir la prosperidad de la familia. Y tal parece ser su función más notable también en el derecho justiniano, que estableciendo (por primera vez, según parece) la obligatoriedad de la equivalencia entre *donatio propter nuptias* y dote, afirmó enérgicamente la paridad de los cónyuges frente a las cargas del matrimonio. La misma paridad se quiso ver observada en los llamados lucros nupciales, cuotas de la *donatio* garantidas en propiedad a la mujer aunque del matrimonio estuviesen por nacer hijos, o cuotas de la dote sustraídas a la obligación normal de restitución y de esta manera garantizadas al marido.

El mismo nombre de *donatio propter nuptias* precede apenas en algunos años al reinado de JUSTINIANO, y corresponde al tiempo en que el gran legislador hacía sus pruebas al lado del tío y antecesor Justino I. Antes se había hablado de *donatio ante nuptias*, y se había excluido que pudiese hacerse después de celebrado el

matrimonio, en obsequio a la prohibición de las donaciones entre cónyuges (cfr. cap. xxvii, § 2); al cambio de nombre responde ahora la norma que permite disponerla o aumentarla también después, como la dote y siempre proporcionalmente a ella, siendo su ya descrita función tal que permite distinguirla claramente de las donaciones entre cónyuges propiamente dichas.

El sistema de los dos aportes iguales, que pueden absorber también todos los bienes de los cónyuges, demuestra —como fué agudamente observado³⁸— una orientación del derecho romano último en sentido opuesto al principio de la separación de los patrimonios vigente en derecho clásico. Hasta qué punto el nuevo sistema se ha aproximado prácticamente a la comunidad de bienes, es un problema que sólo podría resolverse cuando se pudiera establecer para gran número de casos qué parte del patrimonio de los esposos era donada *propter nuptias* y constituida en dote, cuántas veces el patrimonio de uno servía para integrar o sustituir la concesión del otro, cómo las diferentes provincias anticiparon, desarrollaron o, eventualmente, rechazaron la tendencia de que en la legislación justiniana se recoge el esbozo. Pero, en verdad, en algunos documentos egipcios de la época justiniana el régimen de la comunidad está realizado con tan perfecta coherencia como para hacer excluir que pueda tratarse de casos aislados³⁹.

³⁸ BONFANTE, *Lezioni di dir. rom.* (Pavia, 1910-1911), II, p. 158.

³⁹ En un manojo de cartas familiares poco posteriores a Justiniano (años 574 a 613 d. C.), dividido entre las colecciones papirológicas de la biblioteca de Mónaco y del Museo Británico, Paternuthis, marinero de la flota militar, y su mujer Kakô se presentan en muchos documentos (de compraventa, de transacción, de mutuo, de división hereditaria, etc.) como unidos en una comunidad universal de bienes, cuyos intereses son normalmente representados por el marido. Tanto que, por ejemplo, el hermano de ella, Juan, debiendo restituir bienes pertenecientes a la herencia de la abuela, los trasmite a los dos cónyuges conjuntamente (P. Lond., v, 1730), y que otro pariente de ella, cuyo propósito había sido beneficiar a Tapia, madre de Kakô, ha contemplado en su *donatio mortis causa*, para el caso de prefallecimiento de Tapia, no a Kakô misma sino a Paternuthis (nº 1729, *ibid.*). Además, apenas dos años después de las nupcias, los cónyuges se donan reciprocamente para después de la muerte todos sus bienes, en el sentido de que el sobreviviente se haga único titular de ellos, para después transmitirlos a los hijos comunes; la insistencia con la cual éstos se muestran desconfiados obstaculizando la ejecución de las disposiciones, parece denotar alguna duda sobre la validez del acto, que está, en efecto, en contraste con las normas del derecho romano; pero que en realidad la única hija que parece sea nacida del matrimonio no

§ 5. CONCUBINATO Y CONTUBERNIO

Se llama concubinato a la unión permanente entre personas de distinto sexo, sin la intención de considerarse marido y mujer⁴⁰. Semejantes uniones tuvieron en el mundo romano gran difusión, por las prohibiciones que el ordenamiento jurídico decretaba contra ciertos matrimonios, sobre todo de senadores con libertinas, de cualquier ciudadano con prostitutas, de gobernadores de provincia con mujeres de la misma provincia, de los militares, etc. Cuando tales disposiciones prohibitivas no se fundaban sobre una grave exigencia moral, la jurisprudencia no consideraba las uniones en cuestión como reprobables, sino como perfectamente lícitas con la salvedad de que no producían los efectos del matrimonio; por lo cual, por ejemplo, el hijo nacido de concubinato se mantenía *vulgo conceptus*, y la liberta unida en concubinato con su patrón conservaba la facultad de abandonarlo, libertad que

haya hecho oposición, resulta de la circunstancia de que una complicada relación de mutuo, contraída en el año 611 por ambos cónyuges (P. Lond., v, 1736), aparece en el año 613, después de la muerte de Kakô, personificada sólo en Paternuthis. Una organización familiar análoga encontramos, para dos generaciones consecutivas, en otro documento contemporáneo (año 588), P. Cairo Masp. 67158 (*Negotia*, nº 158). Es un contrato de sociedad en el ejercicio del arte de la carpintería; pero las partes son suegro y yerno, y en el contrato intervienen también sus mujeres, y, en fin, el yerno declara su expectativa (*προσδοκία*) de ser un día el heredero y sucesor (*τόν τε κληρονόμον καί διαδόχον*) de ambos suegros: ¿en qué sentido, sino en el de la unificación entre su patrimonio y el de la consorte? Cfr. todavía para otras familias análogamente ordenadas, P. Lond., v, 1708, 1, 29 y ss., y CRUM, *Varia Coptica*, Aberdeen, 1939, nº 5.

No es necesario señalar la importancia de estos datos para la historia de la comunidad entre cónyuges en Italia, últimamente ilustrada por ROBERTI, *Le origini romano-cristiane della comunione fra coniugi*, Torino, 1919. Y quizá en disposiciones como la del P. Cairo Masp. 67158 está también el origen de la *affiliatio* del yerno al suegro, conocida en la Italia bizantina (cfr. los formularios editados por FERRARI en "Bull. Ist. Storico Ital.", 33, 1912, y las observaciones del editor en las ps. 39 y ss.).

⁴⁰ Repito, sustancialmente, la definición común, verdadera tanto para el derecho justinianeo como para el último derecho clásico; pero quien lea atentamente el título del Digesto de concubinis (25, 7), y sobre todo la ley 1 pr., § 3. y la ley 3 pr., advertirá que esta amplia acepción del nombre del concubinato ha sustituido a una restringidísima, conocida todavía a las leyes matrimoniales de Augusto, para la cual concubina era solamente la liberta que convivía con el patrón (cfr. ARANGIO-RUIZ, "Aegyptus", 5, 1924, p. 107).